

DESPIDO

1) Contrato por tiempo indefinido

El contrato de trabajo por tiempo indefinido, originalmente pactado para perdurar en el tiempo, puede, sin embargo, extinguirse en cualquier momento si así lo acuerdan las partes.

Plá Rodríguez recuerda que el contrato de trabajo puede prever de ante mano el derecho de una sola de las partes de rescindirlo, sin derecho a indemnización, aunque limitadamente a un período de tiempo definido. Es el caso del contrato a prueba, en que cada parte autoriza a la otra a rescindir unilateral mente el vínculo. Pero esta situación no debe confundirse con la rescisión por mutuo acuerdo, en que las partes conjuntamente toman la decisión}.

2) Contrato de duración determinada

El contrato puede también tener un momento de extinción acordado en tre las partes al momento de suscribirlo, y en estos casos ya no estaremos en presencia de un contrato por tiempo indefinido, sino ante un contrato de duración determinada³. La característica de los contratos temporales es que su extinción es pactada de antemano (esa extinción puede estar indicada por una fecha cierta o condicionada por el cumplimiento de una tarea o una obra) y la consecuencia principal es que el contrato pierde las garantías de una mayor o menor estabilidad. La extinción natural del contrato temporal se produce por vencimiento del plazo pactado por las partes o por cumplimiento de la obra acordada. Es criterio firme que al no existir propiamente un despido.

Cuando en cambio una de las partes pone fin ante tempus al contrato temporal, surge la cuestión de determinar las responsabilidades por no haber cumplido con el pacto pactado. El caso plantea una ulterior dificultad cuando estamos ante un contrato de obra con fecha de terminación incierta, situación muy común en la industria de la construcción. Como ha expresado Plá Rodríguez, en este caso —en que la extinción del contrato se produce por avance de obra— debe entenderse por terminación «no la totalidad objetiva proyectada por el empleador sino la parte que subjetivamente corresponda al respectivo trabajador dentro de aquella» El caso plantea una ulterior dificultad cuando estamos ante un contrato de obra con fecha de terminación incierta, situación muy común en la industria de la construcción. Como ha expresado Plá Rodríguez, en este caso —en que la extinción del contrato se produce por avance de obra— debe entenderse por

terminación «no la totalidad objetiva proyectada por el empleador sino la parte que subjetivamente corresponda al respectivo trabajador dentro de aquella»⁴. Como ha expresado el TAT 3.º (Sent. n.º 398 de 5/11/2007), el contrato para obra determinada con plazo incierto «es por el tiempo que sean necesarios los servicios del contratado y sabido es que el empleador tiene la facultad de decidir en base a la dinámica de la obra, qué trabajadores se mantienen y quiénes cesan, y en el caso, quedó claro que el cese del actor obedeció al desarrollo normal de la obra en contracción... No debe estarse a la finalización de la obra en su totalidad, sino de las tareas para las cuales fue contratado, y atendiendo a su categoría de peón es evidente que no todos van a cesar al mismo tiempo, aunque sí fueron varios los cesados en esa oportunidad. También quedó claro que no ingresaron nuevos peones luego de la desvinculación del actor»⁵. Debe también señalarse que la jurisprudencia en forma constante ha sostenido la necesidad de que sea el empleador —en los casos del contrato con plazo incierto— quien pruebe el agotamiento del término. Así lo recuerda el TAT 1.º en Sentencia n.º 19 del 12/3/986. En cambio la rescisión unilateral y anticipada de un contrato temporal con plazo cierto, doctrina y jurisprudencias coinciden que corresponderá la reparación del daño producido por quien rescindió el pacto.

Castello y Henderson enumeran cuatro distintos criterios para la liquidación del daño por ruptura ante tempus: a) Aplicación de la indemnización por despido prevista por las leyes de 1944, equiparando la ruptura anticipada al despido común en caso de contrato por tiempo indefinido. b) Aplicación de las reglas del derecho civil en materia indemnizatoria. c) Aplicación de un mecanismo combinado, que deja a opción del trabajador solicitar cualquiera de las dos indemnizaciones anteriores. d) Posibilidad de una reparación acumulativa, es decir indemnización por despido más resarcimiento por daños y perjuicios. Los tres primeros criterios han sido aplicados alternativamente en nuestra jurisprudencia, mientras que el cuarto se ha planteado en la práctica judicial, cuando el trabajador fundamenta la solicitud de la indemnización por despido como un piso mínimo legal, que en caso de no cubrir la totalidad del daño, acumula con la solicitud de daños y perjuicios⁸. Corresponde indicar que la Suprema Corte de Justicia ha aplicado el criterio de los daños y perjuicios del derecho común. En Sentencia n.º 403 del 9/12/97 expresa que la liquidación del daño patrimonial deberá hacerse según los criterios de la reparación integral del daño (arts. 1329 y ss. del Código Civil): deberá cuantificarse el daño producido por la rescisión ante tempus, pero al mismo tiempo deberán descontarse las sumas que el trabajador hubiera percibido en otros trabajos durante el período a considerar.

3) Extinción del contrato por causas independientes de la voluntad de las partes. El contrato de trabajo —ya sea por tiempo indefinido o con duración determinada— está destinado a cumplirse durante el plazo del contrato (contrato a término) o a perdurar sin plazo en el tiempo (contrato por tiempo indefinido). Sin perjuicio de ello, diversas causas —que no derivan de la voluntad unilateral de las partes— pueden poner fin al mismo. Señalaremos a continuación las causas más recurrentes de extinción del contrato:

- a. La muerte del trabajador, ya que el contrato de trabajo es *intuitu personae* a su respecto, pero no respecto de la persona del empleador por lo que cualquier sucesión de parte de este último (por causa de muerte, enajenación de establecimiento comercial, etc. no determina *per se* la extinción del vínculo laboral).
- b. La destrucción de la empresa, el caso fortuito y la fuerza mayor. Larrañaga, en posición recogida por la Suprema Corte de Justicia¹², ha expresado que el hecho que el empleador deba el salario por la prestación del servicio de parte del trabajador implica una obligación de garantía del empleador al trabajador. Aquel que asume la mayor o menor ganancia, asume todo el riesgo, que involucra también la fuerza mayor, en tanto esta viene a constituir un riesgo del empresario¹³. Concluye la Corte en la indicada sentencia que «la rescisión del contrato prevista, debe ser considerada como riesgo de la explotación que el patrono tomó exclusivamente a su cargo frente a los trabajadores, al convenirse entre las partes una retribución forfaitaire, por la cual el trabajador renuncia a las ganancias eventuales de la empresa, pero queda al mismo tiempo, desvinculado de sus riesgos (cf. Rev. Der. Laboral, T. XXV, c. 366, p. 163)». Debe por lo tanto concluirse que aunque el contrato de trabajo se extinga por una calamidad ocurrida a la empresa u otros hechos vinculados con la fuerza mayor o el caso fortuito, esa extinción no exime al empleador del pago de la indemnización por despido.

4) Incapacidad prolongada o permanente del trabajador por accidente, enfermedad común o profesional. Plá Rodríguez recuerda que en general la incapacidad permanente o prolongada se equipara a la muerte del trabajador, en cuanto imposibilita que el mismo continúe desarrollando sus tareas. Sin embargo, no debe perderse de vista.

5) **El concurso de la empresa.** Desde el punto de vista jurídico esta situación se asimila a la muerte del empleador o a los casos de cierre por fuerza mayor o

caso fortuito. La quiebra es una de las posibles consecuencias de la vida de la empresa: es un riesgo que el empleador asumió al promover su emprendimiento. Por lo tanto, en caso de concurso de acreedores, la empresa deberá abonar las deudas laborales, entre las cuales figurará el despido, de conformidad a la normativa que regula la materia (ley 18.387).

6) **Transferencia de la empresa.** Con relación a la transferencia de la empresa corresponde recordar la ley 2.904 del 20.09.1904 que establece requisitos especiales en caso de venta de un establecimiento (publicación por 20 días en dos diarios) y en caso de no cumplirse las mismas, el adquirente responde solidariamente por todas las deudas contraídas por el vendedor, incluyendo las laborales.

7) **Condena penal.** En principio una investigación penal y/o condena por cuestiones externas al contrato de trabajo no pone fin al vínculo, especialmente en aquellos casos en que el trabajador tenía una larga vinculación con la empresa y una conducta intachable. Barbagelata expresa que «el arresto y aun el procesamiento representan circunstancias obstativas del cumplimiento por parte del trabajador de su obligación principal, pero salvo que los hechos que lo provocaron posean significación laboral, el empleador no podría, sin incurrir en responsabilidad, dar por concluida la relación de trabajo». En cambio, cuando la condena es de larga duración —aún por causas externas al vínculo— inevitablemente pone fin al contrato sin derecho a indemnización por la imposibilidad de hecho de continuar con la prestación de las tareas a las cuales el trabajador se obligó.

Extinción del contrato por tiempo indefinido por decisión unilateral de una de las partes

A diferencia del derecho común, el Derecho del trabajo admite la extinción del contrato de trabajo por decisión unilateral de cualquiera de las partes, aunque puede dicha decisión causar daños, de los cuales podrá responderse.

Las causas vinculadas a la voluntad unilateral del trabajador son la renuncia y el abandono, mientras que la decisión del empleador de poner fin al contrato es el despido.

La renuncia

La renuncia es la decisión expresa del trabajador comunicada al empleador de poner fin al contrato de trabajo.

La libertad de trabajo, que —como ha expresado Plá Rodríguez— tiene «profunda raigambre constitucional e internacional» debe primar sobre todo pacto que la limite. La renuncia no es pasible de prohibición ni de limitación pues nadie puede ser obligado a continuar un contrato de trabajo si se desea terminar con el mismo. Es consecuencia del carácter personalísimo del contrato laboral. Este principio —la libertad del trabajador de renunciar al trabajo— puede ser puesto en crisis en situaciones excepcionales, en las que la renuncia es expresión de un actuar de mala fe de un trabajador que ha recibido beneficios especiales bajo la promesa de no interrumpir durante determinado tiempo el vínculo laboral. Ello acontece, por ejemplo, cuando una empresa invierte considerable dinero en la formación del trabajador o cuando la renuncia pueda encontrar su razón en móviles maliciosos.

Con relación a la segunda hipótesis —una renuncia maliciosa— interesa destacar la Sentencia n.º 34 del 2 de junio de 2004 del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1er Turno, que examina el caso de un contrato laboral, por el cual el trabajador (con asistencia de su legal) se comprometía por un alto salario a ocupar determinado puesto gerencial en la empresa por un plazo de cuatro años y en caso de una renuncia antes del vencimiento del plazo se obligaba a abonar a la empresa una indemnización de US\$ 70.000. A los pocos meses el trabajador renunció y los hechos probados indicaban que la renuncia se produjo luego de que el trabajador se apropió de conocimientos confidenciales de la empresa, para ir a trabajar a la competencia. El Tribunal consideró que el vínculo contractual permitió al trabajador conocer la clientela de su empleador, los valores de costo y ganancia de los productos, los sistemas de aprobación y autorización de ventas, etc. por lo que ingresó así en los secretos de los negocios de su empleador. Con estos elementos, el Tribunal consideró que la renuncia fue ilícita y condenó al trabajador a abonar la indemnización a la empresa.

Barbagelata ha dicho que en el caso de la renuncia al empleo, el consentimiento del trabajador — como correctamente exigen los jueces— debe ser libre, espontáneo e inequívoco. «No debe existir coerción —afirma—, ni intención por parte del empleador de defraudar el orden público social... Queda entendido que cuando el empleador fuerza o provoca la renuncia o el abandono del trabajador, esta no es tal, sino que hay despido, pues la voluntad actuante es la del empleador»

La renuncia además debe acreditarse (no alcanzan declaraciones o comentarios verbales hechos a compañeros de trabajo). En tal sentido el Tribunal de

Apelaciones de Trabajo de 2.º Turno expresa que «Cómo enseña el profesor Plá Rodríguez (Curso..., T. II, V. 1, p. 145), es de principio en la materia asegurarse de la autenticidad de la voluntad del trabajador de querer terminar con el contrato de trabajo existente, al punto que en algunas legislaciones para admitir una renuncia al empleo se exige que la misma sea presentada por escrito y ratificada ante la autoridad administrativa, señalando también que ese acto, dada la gravedad de sus derivaciones, debe ser examinado con especial cautela. Y en el caso, esa posible renuncia verbal del actor, estuvo lejos de ser acreditada en forma clara y contundente»

El abandono

El abandono constituye otra forma de extinción unilateral del contrato de trabajo por parte del trabajador. En realidad es una renuncia tácita, porque se expresa por el simple hecho de que el trabajador deja de concurrir a trabajar.

El Tribunal de Apelaciones de 3.er Turno (Sentencia n.º 527 del 17.12.2010, en AJL 2010, c. 564.) recuerda la diferencia entre la renuncia y el abandono: «la iniciativa siempre resulta ser del trabajador, diferenciándose una y otra situación en el hecho de que, en la renuncia hay una manifestación expresa de voluntad y el abandono se configura a través de un comportamiento que no todas las veces resulta inequívoco... en el abandono la voluntad del trabajador tiene que quedar de manifiesto en forma inequívoca; en consecuencia para diferenciarla de un despido debe el empleador accionar los mecanismos legales a su alcance para determinar su voluntad de mantener al funcionario en su puesto de trabajo»

Despido

El despido —es decir la rescisión unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador— constituye de algún modo una paradoja del Derecho del Trabajo.

Plá Rodríguez clasifica distintas modalidades de despido: **a) Directo:** el empleador comunica expresamente el despido; puede también comunicarse con hechos (por ej., el retiro de la tarjeta del reloj) o efectuado por el representante del empleador. **b) Indirecto:** hay una violación del contrato de trabajo por parte del empleador, en forma deliberada (por ej., jus variandi ilícito) o no deliberada (por ejemplo, atraso en el pago de los salarios provocado por una coyuntura económica adversa). **c) Técnico:** según De Ferrari es el caso del trabajador que sigue trabajando en una empresa que ha cambiado de dueño. **d) Administrativo:** según Deveali hay despido administrativo cuando al trabajador se le paga el

despido y luego se le cambia de tarea o se cambia el sueldo y sigue trabajando en la misma empresa. Con posterioridad a la clasificación de Plá Rodríguez, es posible agregar otras dos modalidades de despido: **e) Ficto:** es el previsto por el art. 9 del decreto-ley n.º 15.180 (seguro de desempleo), y se produce por la no reincorporación del trabajador luego de los plazos de suspensión por falta de trabajo. **f) Abusivo.**

Notoria mala conducta

La ley n.º 10.489 de 6/6/1944 que crea el régimen de despido tarifado para los trabajadores mensuales, expresa al final de su art. 4 que «los beneficios de este artículo no alcanzan a los obreros y empleados que sean despididos por notoria mala conducta». La extensión posterior del régimen (Leyes n.º 10542 del 20/10/1944 y 10.570 del 15/12/1944) a los obreros, destajistas y jornaleros significó también extender la eximente de la notoria mala conducta a estos trabajadores.

Importa también recordar el art. 10 de la ley n.º 12.597 del 20/11/1958, que expresa: «Todo trabajador que fuera despedido por notoria mala conducta, no tendrá derecho a indemnización por despido. El empleador deberá probar los hechos constitutivos de la notoria mala conducta». La norma confirma la idea que la notoria mala conducta es una excepción y por lo tanto debe ser probada por quien la invoca, es decir el empleador.

Barbagelata expresa que por notoria mala conducta debe entenderse «la que independientemente de toda otra consideración, pone en crisis la relación de trabajo por culpa del trabajador. Esta crisis puede ser consecuencia de un clima provocado por pequeñas faltas frecuentemente reiteradas o puede ocurrir de golpe por la incursión de una falta de excepcional gravedad. La mala conducta a que se refiere la ley es pues una mala conducta especial que se concreta en una o varias faltas del trabajador según la entidad de estas»

Concepto legal. Los hechos constitutivos de la notoria mala conducta —indica Plá Rodríguez— deben tener determinadas características: 1. Deben ser voluntarios e imputables al trabajador (no es voluntaria, por ejemplo, la embriaguez que se produce por pegamentos tóxicos en el lugar de trabajo). El Tribunal de Apelaciones de 2.º Turno ha recordado que «los hechos —para merecer tal calificativo (de notoria mala conducta)— deben reunir las siguientes características. Deben ser hechos voluntarios, de los cuales pueda ser responsabilizado el trabajador»⁴⁸. 2. Relacionados con la actividad laboral (o en

el desempeño del trabajo o que repercuten en él). Excepcionalmente pueden ser hechos de la vida privada del trabajador (ejemplo, cajero, que todas las noches juega en el Casino). 3. Deben tener una gravedad tal de imposibilitar la continuación del contrato. La jurisprudencia dice que debe «poner en crisis el contrato de trabajo». 4. Con relación al número la conducta puede resultar de un solo hecho suficientemente grave (por ejemplo, un trabajador roba en la empresa o agrede físicamente a un superior), o producirse por la reiteración de varios hechos en sí no gravísimos (por ejemplo, reiteración de llegadas tardes), pero cuya continuidad y progresividad definan la notoriedad de la inconducta. 5. La apreciación siempre debe ser efectuada por el juez, quien apreciada la prueba determina si resulta probada la eximente o, en caso contrario mandará abonar al empleador la correspondiente indemnización por despido. 6. Deberá tenerse en cuenta a la hora de apreciar la inconducta diversos elementos como los antecedentes del trabajador, su antigüedad, su nivel cultural, etc. Barbagelata señala que «la apreciación de la conducta debe cumplirse teniendo en cuenta factores de índole diversa y que se encuentran dosificados y combinados en forma siempre distinta. Así, es necesario pesar la antigüedad en el empleo, la categoría laboral, los comportamientos anteriores, la disciplina del establecimiento, la existencia o inexistencia de reglamento interno, los móviles o causas de las faltas imputadas, etc.»

La enumeración de las hipótesis de notoria mala conducta es amplísima y a vía de ejemplo indiquemos algunas de ellas, según lo consignan los Anuarios de Jurisprudencia Laboral: faltante de dinero, acoso sexual, agresión a un superior, retiro de mercadería no autorizada de la empresa, ebriedad en horas de trabajo, competencia desleal, riñas, destrato hacia el jefe, llegadas tardes, falta de rendimiento intencional, adulteración de documentación, ausentarse del trabajo sin autorización, dañar la imagen de la empresa, etc. Obviamente en cada caso deberá analizarse la hipótesis para definir su gravedad a la luz de los hechos ocurridos, su eventual reiteración y los antecedentes del trabajador.

Por último corresponde indicar las consecuencias que trae aparejada la notoria mala conducta para el trabajador: 1. La principal y más grave de ellas, es que el empleador —como se dijo— pierde la indemnización por despido que acompaña normalmente la extinción del contrato por decisión del empleador. Pierde además el aguinaldo. En efecto el art. 3 de la ley 12.840 del 22/12/1960 reconoce el derecho al cobro del aguinaldo generado al momento de la finalización de la relación laboral, sea por renuncia, jubilación o despido, salvo en caso de notoria

mala conducta. 2. El trabajador también pierde el derecho a acogerse al seguro de paro. Es el art. 4 del decreto-ley 15.180 de 20/8/1981, que —al establecer las «exclusiones» al derecho de percibir el subsidio por desempleo— incluye la situación de «los que fuesen despedidos o suspendidos por razones disciplinarias de acuerdo a lo que determina la reglamentación». La norma en este caso no habla de notoria mala conducta, pero es evidente que por razones disciplinarias puede incluirse inconductas que no alcance el grado de evidencia de la notoria mala conducta. Señalemos que el decreto 14/982 del 19/1/82 en su art. 9 enumera a modo de ejemplo una lista de inconductas que privan de la percepción del seguro»

Cálculo de la indemnización por despido

Por aplicación del artículo 1.440 del Código Civil, se entiende que el empleador debe pagar los rubros de egreso dentro de los diez y siguientes a la fecha del cese.

Despido del trabajador mensual

El régimen de despido del trabajador mensual se encuentra regulado por el art. 4 de la ley 10.489 y el art. 13 del decreto-ley 14.188. De la lectura de los textos referidos resulta que, en caso de despido, el trabajador mensual tiene derecho a una indemnización equivalente a la remuneración total correspondiente a un mes de trabajo por cada año o fracción de actividad con el máximo de seis mensualidades.

Debe tenerse presente que si bien no existe texto legal, la jurisprudencia ha determinado que no se debe el pago del despido si el trabajador mensual no ha alcanzado al menos los 90 días.

Mensualidades

La antigüedad que el legislador tomó en consideración es el «año o fracción de actividad». El año de antigüedad se computa desde el ingreso del trabajador, son años aniversario, contados desde el inicio de la relación laboral al cese, según lo prevé el art. 2 de la ley 12.597. No interesa que ocurrió dentro de cada año de trabajo. Es decir, si el trabajador efectivamente prestó servicios, o estuvo en el seguro de paro, accidente de trabajo u otra causa de suspensión del vínculo laboral. La ley solo ordena analizar el día de inicio de la relación y el día del despido, y computar los años transcurridos en ese período. En lo que refiere a la fracción, es importante tener en cuenta que el legislador no exigió ningún mínimo

de duración. Por lo tanto, basta un día para que se genere la «fracción de año» que da derecho a una unidad de despido.

Al superar el período de prueba, ya puede hacer efectivo el cobro de al menos una mensualidad, al alcanzar un año y un día tendrá derecho a dos mensualidades y así sucesivamente. Y a los cinco años y un día habrá llegado a la indemnización por despido máxima (seis mensualidades).

La remuneración total correspondiente a un mes de trabajo

No existe norma, legal o reglamentaria, que defina el concepto de remuneración total correspondiente a un mes de trabajo. Han sido doctrina y jurisprudencia quienes, con el transcurso de los años, han ido desentrañando y elaborando el concepto.

La base económica del despido debe estar conformada por el sueldo base vigente a la fecha de despido, más todas las partidas de carácter salarial percibidas por el trabajador en un mes de trabajo, sean fijas o variables, en dinero o en especie.

Además de los elementos marginales del salario, para conformar la mensualidad deberá incorporarse lo que el trabajador gana en un mes en concepto de licencia, lo que gana en igual período en concepto de salario vacacional y lo que también gana en un mes en concepto de aguinaldo. Ello en mérito a que el legislador ordena computar la remuneración total de un mes. O sea, todo lo que el trabajador gana en un mes de trabajo. Y, en cada mes de trabajo, no solo se gana sueldo, viáticos, horas extras (o cualquier otra partida que aplique al trabajo desarrollado), sino que, también, se gana licencia, vacacional y aguinaldo.

Elementos fijos

Estos elementos, que el trabajador recibe mes a mes de idéntica manera, se incorporan, al igual que el sueldo base, por el monto que tengan a la fecha de extinción del vínculo laboral.

En caso que el elemento fijo sea en especie, deberá incorporarse por su valor equivalente en dinero. Hay beneficios en especie cuya estimación económica es sencilla. Así, los tickets de alimentación o la cuota mutual son de fácil inclusión en la base de cálculo del despido. Se deberán tomar por su valor al cese.

En otros casos su estimación no es tan sencilla. Así por ejemplo, el beneficio de uso de una vivienda de propiedad del empleador, o el uso de un vehículo con libre disponibilidad, son beneficios de más difícil estimación¹. A estos efectos

entendemos que deberá buscarse su valor dinerario real, evitando la utilización de los fictos de seguridad social, ya que su inclusión debe hacerse teniendo presente lo que los mismos representan como ventaja económica para el trabajador.

Elementos variables

Dentro de las partidas variables se incluyen todos aquellos beneficios salariales que el empleado no percibe de manera fija. Dentro de estos se encuentran las comisiones, las primas por presentismo, rendimiento o productividad y las propinas.

Para la incorporación de las partidas variables debe estarse a lo previsto por el art. 28 del decreto de fecha 10/11/1944. La norma dispone que la inclusión se realice calculando el promedio percibido por el empleado en concepto de remuneración variable en el año o fracción de año inmediato anterior al cese. Es decir, que la suma a incorporar a la mensualidad resultará de sumar lo ganado en concepto de remuneración variable en los 12 meses calendario anterior al despido, o fracción de año si no alcanzó a cumplir los 12 meses de trabajo, y dividirlo entre 12 o los meses de la fracción de año en su caso.

Viáticos

Para determinar si corresponde la inclusión de los viáticos en la mensualidad o remuneración total de un mes, lo primero que debe hacerse es discernir si se trata de viáticos de naturaleza salarial o indemnizatoria.

Los viáticos de naturaleza indemnizatoria no se incorporan porque no tienen carácter remuneratorio, sino que son un simple reintegro del gasto en que incurrió el trabajador por motivo del trabajo.

Los viáticos a forfait o por partida global, es decir, aquellos que se entregan al trabajador sin tener que rendir cuentas de su utilización, tienen carácter salarial. En tanto representan una ventaja económica para el trabajador, ya que este no debe reintegrar la parte del viático que no haya gastado.

A falta de una norma laboral que determine la cuota parte salarial de estos viáticos, doctrina y jurisprudencia en forma pacífica, recurren a las normas que regulan la gravabilidad de esta partida a los fines de la seguridad social. En tal sentido el art. 157 de la ley 16.713 prevé que los viáticos a forfait están gravados al 50 % de la suma efectivamente percibida cuando son otorgados para ser

utilizados en el país, y en un 25 % cuando se otorgan para ser utilizados en el exterior.

Horas extras

La ley de horas extras (15.996 del 17/11/88) establece en su art. 3 que las sumas pagas por concepto de horas extras tienen naturaleza salarial. Por tanto su inclusión para el despido resulta mandataria, más allá de que se realicen las mismas en forma habitual o excepcional. Ni la ley ni su decreto reglamentario (550/89) regulan como debe realizarse la incorporación de las mismas. Afirmamos que para su consideración en el despido deberá tomarse el promedio de las horas extras realizadas en los doce meses anteriores al despido, o fracción de año si no se alcanzó el año de antigüedad.

O sea que, primero, debe sumarse el total de horas extras realizadas en los últimos 12 meses anteriores al despido o fracción de año si no se alcanzaron los 12 meses de antigüedad. Deben sumarse por separado las horas extras realizadas en día hábil de las realizadas en día inhábil. Una vez obtenido el total de cada una de las horas extras trabajadas, se deberá dividir cada total entre 12 o los meses que correspondan según el caso. Los promedios de horas extras obtenidos deberán multiplicarse por el valor de la hora extra (en día hábil o inhábil según corresponda) vigente al día del despido. Es decir, promedio de horas extras en día hábil por valor de la hora extra vigente al día del despido; y promedio de horas extras en día inhábil por valor de la hora extra en día inhábil a esa misma fecha.

Incidencia de licencia, salario vacacional y aguinaldo

Dicho de otra forma, al momento de calcular la alícuota de licencia deberá estarse a lo previsto en la ley de licencia para el cálculo del sueldo de vacaciones. Cuando deba buscarse la incidencia del vacacional habrá que estar a lo dispuesto por las normas de salario vacacional. Y finalmente, para obtener lo ganado por aguinaldo en un mes de trabajo habrá que proceder conforme lo establecido en la ley que lo regula.

Si se calcularan las alícuotas tomando solo el sueldo base se incluirían en la remuneración total correspondiente a un mes de trabajo una suma menor de lo realmente ganado por el trabajador en un mes por concepto de licencia, vacacional o aguinaldo.

- a) **Alícuota de licencia**. Por concepto de alícuota de licencia lo que debe integrarse es lo que por tal concepto el empleado gana en un mes de trabajo.

Para buscar la cantidad de días de vacaciones que el trabajador genera por mes habrá que apreciar la fecha de ingreso y la de egreso. En función de ello se sabrá si el empleado genera 20 o más días de vacaciones, conforme lo previsto por la ley 12.590. Una vez que se determinaron los días que se generan por año (20, 21, 22 o los que correspondan en función de la antigüedad) deberá dividirse el número entre 12 (por ejemplo, 20 dividido 12). El valor resultante (en el caso, 1.66) serán los días de licencia que el trabajador genera por mes. Se deberá tomar el sueldo base mensual, más todos los elementos marginales de salario que perciba el empleado en un mes (promedio de horas extras; cuota parte salarial del viático; equivalente en dinero de las partidas en especie; promedio actualizado de las partidas variables). Luego deberá dividirse el sueldo de licencia entre 30, para obtener el jornal de vacaciones, tal como ordena el art. 10 de la ley 12.590. Finalmente, se deberá multiplicar el jornal de vacaciones por la cantidad de días de licencia generados por el trabajador en cada mes de trabajo.

- b) **Alícuota de salario vacacional.** Conforme a la ley 16.101, el salario vacacional equivale al 100 % del jornal líquido de vacaciones. Por su parte, el decreto reglamentario de la ley de salario vacacional (615/89) en su art. 3 prevé que el jornal líquido de vacaciones es el resultante de restar al jornal nominal de vacaciones los aportes de contribuciones de seguridad social. En tanto la alícuota de salario vacacional equivale a lo que se gana en un mes por salario vacacional, su fórmula de cálculo será jornal nominal de licencia (sueldo de licencia dividido 30) menos aportes de seguridad social por los días de licencia que el trabajador genera en un mes en función de su antigüedad (por ejemplo, 20 dividido 12). Dicho de otra forma, la alícuota de salario vacacional es igual a la alícuota de licencia menos los aportes de seguridad social.
- c) **Alícuota de aguinaldo.** Para su cálculo deberá tenerse presente lo previsto por el art. 2 de la ley 12.840, en tanto dispone que el aguinaldo se obtiene tomando las partidas remuneratorias en dinero pagas por el empleador. En definitiva, la alícuota de aguinaldo será equivalente a la suma de todas las partidas remuneratorias en dinero pagas por el patrono en un mes dividido 12. A veces se cuestiona el criterio descrito indicando que si se toma solo lo ganado en el último mes la alícuota puede no ser representativa ya que en ese mes el trabajador puede haber recibido partidas que no recibió en los anteriores meses, o al revés. Una opción es tomar para la alícuota los montos de los beneficios remuneratorios en dinero pagos por el patrono

que ya se obtuvieron para la conformación de la mensualidad. Es decir, sumar al sueldo base del cese y a las partidas fijas en dinero lo que se obtuvo, por ejemplo, por promedio de horas extras o por promedio de comisiones. Una forma más exacta de calcular la alícuota de aguinaldo es partiendo del aguinaldo de egreso a que tiene derecho el empleado despedido. Para obtener la alícuota a través de este procedimiento, primero, entonces, es necesario calcular el aguinaldo que corresponde abonar al empleado como aguinaldo de egreso. Y, luego, dividir el monto obtenido entre los meses a los que dicho aguinaldo corresponde. Así, por ejemplo, si el despido ocurre el 31 de marzo, primero se calcula el aguinaldo a pagar (sumando todo lo ganado en dinero pago por el empleador desde el 1/12 del año anterior al 31/3 —excluyendo las participaciones y el propio aguinaldo— y dividiéndolo entre 12). El resultado obtenido es el aguinaldo de egreso. Dicho monto se deberá dividir entre 4 (por ser los meses a que corresponde el aguinaldo del ejemplo, 1 de diciembre al 31 de marzo) para así obtener el aguinaldo de un mes, es decir, la alícuota a sumar a la remuneración total de un mes.

Despido del trabajador jornalero, destajista y por hora

El régimen de los trabajadores jornaleros, remunerados por día y a destajo se encuentra regulado en las leyes 10.542 del 20/10/44, 10.570 del 15/12/44 y 12.597 del 30/12/58.

En el caso de los trabajadores jornaleros y los remunerados por hora antes de proceder al cálculo de la indemnización deberá hacerse la reducción a salario por día. A estos efectos, en el caso del destajista, deberá dividirse el total ganado por el número de jornadas laboradas, llegando así al valor del jornal a utilizar. En el remunerado por hora se sumarán todas las horas laboradas y se dividirá el resultado obtenido entre el total de días trabajados; el resultado se multiplicará por el valor hora vigente al cese, logrando así el valor del jornal a utilizar para el cálculo del despido.

A diferencia del trabajador mensual, el jornalero tiene un período de carencia para adquirir derecho a indemnización por despido. La norma dispone que para tener derecho a indemnización por despido el trabajador deberá haber laborado un mínimo de 100 jornadas en el establecimiento. Es decir, que el derecho a indemnización lo adquiere a partir del momento que alcanza 100 jornales de antigüedad.

Bases para la determinación de los jornales trabajados

La norma dispone que el trabajador jornalero tendrá derecho a una indemnización por despido equivalente a 25 jornales por cada año de trabajo en que alcance 240 o más jornales trabajados. Y que, en aquellos años que no alcance los 240 jornales trabajados le corresponderán 2 jornales de indemnización por cada 25 jornadas trabajadas. El máximo de indemnización a que tiene derecho el jornalero es de 150 jornales.

A los solos efectos del despido la ley establece que los años a tomar en cuenta se conforman partiendo del despido hacia atrás. En consecuencia lo primero que deberá hacerse es conformar los años trabajados partiendo del día del egreso hasta llegar a la fecha de ingreso.

Conformados los años de la manera expresada deberá examinarse lo ocurrido en cada año. Sumar los días efectivamente trabajados en cada uno de esos años. Además deberán sumarse los días que el trabajador haya percibido salario en todo o en parte, con motivo de accidente de trabajo, enfermedad profesional, vacación anual o feriados pagos, por así disponerlo el art. 9 de la ley 12.597. Asimismo, conforme al art. 21 del decreto-ley 14.407, deberá sumarse el tiempo que el trabajador no pudiera prestar servicios por razones de enfermedad común.

a) La llamada indemnización por despido común es la que corresponde aplicar cuando el trabajador jornalero alcanzó 240 o más jornadas trabajadas en cada uno de los años de vigencia de la relación laboral. En este caso tendrá derecho a 25 de jornales de indemnización por cada año, con un máximo de 150 jornales.

b) La indemnización por despido promedial aplica cuando, pese a existir años en los que se trabajó menos de 240 jornadas, el promedio anual de jornadas trabajadas en el período no resulte inferior a 240. Si el resultado obtenido es igual o superior a 240 jornadas, entonces, se otorgará al jornalero una indemnización de 25 jornales por cada uno de los años tomados en cuenta, con el máximo de 150 jornales.

c) Finalmente, corresponderá aplicar la indemnización por despido parcial cuando no solo el jornalero no haya trabajado 240 jornadas o más en todos los años de la relación, sino, que tampoco se alcance el número de 240 jornadas trabajadas al realizar el promedio de jornales, en la forma que se describió en el literal anterior.

En este caso se considerará cada año trabajado en forma individual. Y, en aquellos años en los que haya laborado 240 o más jornales le corresponderá 25 jornales de indemnización, y en los años que no haya alcanzado los 240 jornales le corresponderá una indemnización equivalente a 2 jornales cada 25 trabajados. A efectos de determinar la cantidad total de jornales de indemnización a abonar al trabajador el único límite es que no podrán pagarse más de 150 jornales de indemnización. Ello determina que la cantidad de años a considerar 333 Leonardo Slinger no está acotada a los últimos seis. Sino que, pueden tomarse todos los años del despido al ingreso que pueda haber laborado el trabajador, aplicando las reglas de 25 jornales en los años que trabajó 240 o más jornadas y 2 cada 25 cuando no alcanzó las 240, hasta alcanzar el máximo de indemnización de 150 jornales.

Las fracciones inferiores a 25 jornadas no generan derecho a indemnización alguna. Son dos jornales cada 25 trabajados, y no 1 cada 12 días. Así por ejemplo, un año en que el trabajador alcanzó las 75 jornadas trabajadas le dará derecho a 6 jornales de indemnización (2 cada 25), y un año en el que trabajó 90 le dará también 6 jornales (2 cada 25, sin generar derecho alguno por los 15 jornales restantes)

La determinación del jornal de indemnización por despido

El jornal base de indemnización por despido se conformará por la remuneración total de un día de trabajo. Así el jornal vigente al cese será el primer concepto a incorporar a la remuneración base de despido, pero, no el único. A la misma se deberán sumar todas las partidas en dinero o especie, fijas o variables, que el trabajador gane en un día, así como el promedio diario de horas extras, la parte salarial del viático a forfait que pueda percibir, y lo que en un día gana en concepto de licencia, salario vacacional y aguinaldo. Es el mismo criterio descrito para el trabajador mensual, solo que, en el caso del jornalero todo se hace en base a un día.

Alícuota licencia jornalero, destajista

A estos efectos se buscará los días que genera por año, en función de la antigüedad que tenga. Ese número de días (20, por ejemplo) se dividirá entre 12 para obtener la cantidad de días que genera por mes (en el ejemplo: $20 \div 12 = 1,66$). 335 Leonardo Slinger Finalmente, la cantidad de días que genera por mes se divide entre 25 para, así, saber, el tiempo de licencia que genera en cada día de trabajo (en el ejemplo: $1,66 \div 25 = 0,0666$). La alícuota de licencia será el

resultado de multiplicar el jornal de vacaciones por el tiempo de licencia que el jornalero genera en un día (jornal de vacaciones $\times$ 0,0667, en el ejemplo).

Alícuota salario vacacional jornalero, destajista

Jornal de vacaciones — Aportes de seguridad social $\times$ 0,066.

Alícuota de aguinaldo jornalero, destajista

Es lo que en un día de trabajo el trabajador genera en un día de aguinaldo. Se puede obtener sumando todo lo que el trabajador percibe en un día en dinero de carácter remuneratorio y pago por el patrono, y luego dividiendo el resultado obtenido entre 12.

Monto despido jornalero, destajista

Para determinar el despido a abonar deberá multiplicarse la referida remuneración por la cantidad de jornales de indemnización por despido que tenga derecho a percibir el trabajador jornalero (es decir, el número de jornales de IPD resultante luego de aplicar la indemnización por despido común, promedial o parcial, según sea el caso).

DESPIDO ABUSIVO

El abuso de derecho presume la existencia de un derecho; en el caso del despido no existe el tal «derecho de despedir»: en el despido sin justa causa hay la contravención a un derecho del asalariado —el derecho a la conservación del empleo— frente a su empleador.

En su libro Derecho del Trabajo, Barbagelata afirma en 1977 que la indemnización por despido forfaitaire cubría solo el daño normal del despido, pero que era posible aplicar indemnizaciones complementarias, en función de la forma y oportunidad que opera el despido, la condición del trabajador, el móvil del empleador, etc.

El desarrollo doctrinario y el reconocimiento jurisprudencial a partir de 1986 determinan que hoy ya nadie discute la posibilidad de condenar al empleador al pago del daño moral que puede provocar el hecho del despido (más allá de la propia pérdida del trabajo). También se habla recurrentemente de despido abusivo, porque se sostiene en forma mayoritaria que la justificación de la acumulación de la reparación reposa en el art. 1321 del Código Civil, donde se afirma que el que usa de su derecho no daña a otro, con tal que no haya exceso de su parte.

Despido abusivo y daño moral. Estos dos conceptos son jurídicamente distintos, pero no es fácil separarlos al hablar del despido abusivo. En la casi totalidad de los casos, el despido abusivo implicará un daño que afecta el honor, la intimidad, la personalidad del trabajador, con una carga de sufrimiento o dolor difícilmente evaluable.

Mangarelli ha expresado que la indemnización del daño moral es *in re ipsa*, porque es la consecuencia de una actitud abusiva, que no requiere otra prueba específica.

La prueba del despido abusivo

El despido abusivo no se presume, por lo cual la carga de la prueba corresponderá a la parte trabajadora. La jurisprudencia ha expresado que «quien pretende el cobro de una suma superior a la legalmente tarifada debe probar ese daño mayor que haría lugar a una reparación distinta, ese hecho antijurídico, ese dolo, malicia o ánimo de daño»

Evaluación del daño moral por despido abusivo

montos de indemnización que atienden a la circunstancias del caso. La jurisprudencia nacional se ha ido alineando en forma unánime hacia el criterio de estimar el daño producido por el despido abusivo en una o más unidades del despido común. En general, y atendiendo la gravedad del caso, los jueces han evaluado el daño de una a tres unidades de la IPD común, que se suman a esta, tomando en cuenta las circunstancias del caso.

La Corte resume algunas reglas sobre los requisitos para que se configure el abuso y se justifique por lo tanto una indemnización superior a la tarifada. La Corte adhiere a una posición restrictiva y muy precisa en materia de los requisitos necesarios para que opere el despido abusivo. Ellos son: a) el despido abusivo no ocurre por falta de causa, sino que requiere algo más: la existencia de causa ilícita contraria a derecho, motivada en cuestiones extralaborales; b) el despido abusivo se configura en aquellos casos en que resulta particularmente chocante o arbitrario; c) debe quedar reservado a situaciones excepcionales de abuso flagrante o notorio del derecho a despedir que nuestro ordenamiento legal laboral otorga al patrono. d) ante la ausencia de definición legal acerca de cuáles son los límites del derecho de despedir («derecho reconocido por nuestro derecho positivo»), más allá de los cuales su ejercicio se torna abusivo, la Corte reitera criterios anteriores al afirmar que el despido no es abusivo cuando no hay una situación

de violación grosera, inmotivada o provocada por móviles extralaborales, los que de existir, sí permitirían la admisión de una pre tensión de ese contenido. e) No es suficiente que el despido parezca como injustificado para que se configure una hipótesis de despido abusivo, sino que el trabajador debe probar que existió dolo, culpa o negligencia por parte del empleador; f) el despido abusivo o ejercicio abusivo de rescindir el contrato de trabajo, implica causas dolosas, ilícitas, mal intencionadas y con ánimo de dañar económica o moralmente al trabajador. g) El amparo del rubro requiere además probar la intención de perjudicar o menoscabar al trabajador.

Compatibilidad despido abusivo y despido indirecto

La compatibilidad entre el despido abusivo y el indirecto —controvertida por muchos jueces en las primeras sentencias sobre el daño extratarifario— fue reconocida a partir de la sentencia n.º 364 de la Suprema Corte de Justicia del 12/11/1997.

Debe tratarse de una situación excepcional. El despido indirecto se resarce por regla, únicamente con la indemnización por despido tarifada, y eventualmente se puede adicionar otra indemnización de daños y perjuicios. Para poder solicitar la referida acumulación, deben reunirse determinados requisitos: a) el incumplimiento grave del empleador debe lesionar otros intereses del trabajador protegidos por el ordenamiento laboral, b) y el daño —en el caso de que se trate de daño moral— tiene que tener entidad (las sensaciones de indignación, contrariedad, angustia, etc. que produce el incumplimiento contractual no se reparan). Las situaciones en las que es posible reclamar la indemnización común por despido indirecto y otra indemnización complementaria de daños y perjuicios podrán ser las siguientes: incumplimientos motivados en persecución política, religiosa, en razones antisindicales o cualquier otro motivo antijurídico, o si existe una especial intención de dañar, o si el comportamiento del empleador es particularmente antijurídico o si por los medios utilizados se violentaron otros intereses del trabajador tutelados por el derecho laboral.

DESPIDOS ESPECIALES

Despido especial por gravedad

La normativa básica que regula la protección ante el despido y los cambios abusivos de las condiciones de trabajo de la misma, se encuentra contenida en los arts. 16 y 17 de la ley n.º 11.577 del 14 de octubre de 1950, los arts. 11 a 17

del decreto-ley n.º 15.084 del 28 de noviembre de 1980, la ley n.º 17.215 del 24 de setiembre de 1999, la ley n.º 18.868 del 23 de diciembre de 2011, ley 19.161 de 15 de noviembre de 2023, ley 20.000, ley 20.312, ley 20.377 y el Convenio Internacional del Trabajo n.º 103 sobre protección de la maternidad de 1952, ratificado por la ley 12.030 del 27 de noviembre de 1953.

El art. 16 de la ley n.º 11.577 dispone que «toda mujer en estado de gravidez tendrá derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable según prescripción médica. Si la ausencia del trabajo durare menos de cuatro meses, tendrá derecho al salario íntegro de la ausencia. Si excediere de ese plazo, ganará medio salario hasta el término de seis meses. El empleo deberá ser conservado si retornare en condiciones normales», en tanto que el art. 17 dispone que «en el caso previsto en el artículo anterior, la obrera no podrá ser despedida. Si lo fuere, el patrón deberá satisfacer un importe equivalente a seis meses de sueldo más la indemnización legal que corresponde»

La ley n.º 17.215 dispuso que la trabajadora que se encuentre en estado de gravidez o en período de lactancia tiene derecho a obtener un cambio temporario de las actividades que desempeña, cuando las mismas, por su naturaleza o por las condiciones en que se llevan a cabo, pudieren afectar la salud de la trabajadora o de su hijo. Este cambio de tareas no puede implicar disminución o aumento de la remuneración que habitualmente percibe la trabajadora

La ley n.º 18.868 establece que «se prohíbe exigir la realización o presentación de test de embarazo o certificación médica de ausencia de estado de gravidez, como requisito para el proceso de selección, ingreso, promoción y permanencia en cualquier cargo o empleo, tanto en la actividad pública como privada. Asimismo, se prohíbe la exigencia de toda forma de declaración de ausencia de embarazo» (art. 1) y que «El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior merecerá, por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la aplicación de las más severas sanciones administrativas, pecuniarias o de la naturaleza que corresponda» (art. 2).

Las progenitoras de aquellos nacidos sin vida con más de veinte semanas de gestación o con un peso superior a quinientos gramos tendrán derecho a la licencia maternal (Ley número 20.377).

Si bien el art. 17 de la ley n.º 11.577 dispone que «la obrera» que se encuentre en uso de licencia maternal no podrá ser despedida, la doctrina y la jurisprudencia han entendido pacíficamente que la protección alcanza también a las

«empleadas» o más propiamente, a toda trabajadora dependiente sin distinción de clase alguna de categoría, jerarquía o actividad.

En concreto, la indemnización especial se torna exigible cuando el despido se verifica: a) durante el período de gravidez; b) durante el período de licencia maternal, tanto la regular o común (identificada más abajo), como la de carácter suplementario o extraordinario derivada de complicaciones del embarazo o parto; c) por un período de tiempo razonable posterior al reintegro al trabajo, luego de la licencia maternal.

Subsidio por maternidad y especificación de licencias

Esta prestación económica ampara a la trabajadora durante su licencia maternal. El subsidio es sustitutivo del salario y cubre los 98 días de licencia (pre y posparto).

Beneficiarias

- Trabajadoras dependientes de actividad privada incluyendo bancarias y personal de embajadas.
- Trabajadoras no dependientes y cónyuges colaboradores de Industria y Comercio hasta con un dependiente.
- Trabajadoras no dependientes y cónyuges colaboradoras Rurales hasta con un dependiente.
- Titular o cónyuge colaboradora de empresas monotributistas.
- Representantes legales de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) (VF 124), administradores SAS (VF 120) y directores con remuneración SAS (VF 121) hasta con un dependiente.
- Docentes del Colegio y liceo Elbio Fernández de aportación civil.
- Directores de sociedades anónimas con remuneraciones.
- Trabajadoras que habiendo sido despedidas quedaran embarazadas durante el período de amparo al Subsidio por desempleo.
- Contrato laboral Inc. 2 a 15 Administración central, vínculo funcional 94.
- Titulares monotributistas Mides.
- Socias Cooperativistas

La suspensión o extinción de la relación laboral durante el período de gravidez o descanso puerperal, por razones ajenas a su voluntad, no afectará la percepción íntegra del subsidio.

Cuando la pareja es conformada por dos mujeres, el subsidio por maternidad le corresponde a la gestante, mientras su cónyuge o concubina tiene derecho al subsidio por paternidad.

La persona deberá permanecer en el país durante el período del subsidio, salvo casos excepcionales por motivos de salud, que serán evaluados por el área correspondiente.

Las progenitoras de aquellos nacidos sin vida con más de veinte semanas de gestación o con un peso superior a quinientos gramos tendrán derecho a la licencia maternal (Ley número 20.377).

Período de amparo

La licencia comenzará seis semanas antes de la fecha presunta de parto (42 días de preparto) y se extenderá hasta ocho semanas después del parto (56 días posparto).

Cuando uno de los integrantes de la pareja (de igual o distinto sexo) participa del proceso biológico de reproducción, pero ninguno participa en la gestación, se deberá hacer opción de roles. En estos casos, el subsidio por maternidad cubrirá las 8 semanas posteriores al parto. A la mujer gestante que interviene en el proceso de reproducción y tiene actividad válida, le corresponde el subsidio por maternidad común (98 días de licencia).

En los casos de complejidad, que impliquen riesgo de vida o que, a juicio del médico especialista, requiera de los cuidados de la madre, independientemente de la semana de gestación, en los nacimientos múltiples, de bajo peso (menor o igual a 1,5 kg) o partos prematuros hasta las 33 semanas de gestación inclusive, se podrá extender el período de amparo de acuerdo a lo establecido en la Ley n.º 20.000. Esta ley es de aplicación para los nacimientos a partir de su entrada en vigencia (04/12/2021), así como para aquellos que aún se encontraran al amparo del subsidio a esa fecha.

En el caso de trabajadoras dependientes, el derecho a los períodos de descanso por maternidad es obligatorio e irrenunciable.

Monto a percibir

- Es el 100 % del promedio diario o mensual de las remuneraciones percibidas en los seis meses anteriores, más la cuota parte correspondiente a licencia, aguinaldo y salario vacacional generado durante el período de amparo.
- Para los titulares de empresas, monotributos, etc., se liquidará el promedio mensual de sus asignaciones computables de los últimos 12 meses. Deberán estar al día con sus aportes a BPS.

El subsidio quedará otorgado el día de inicio de la licencia. Se efectuará un solo pago por todo el período y estará disponible para su cobro de acuerdo al [calendario de pagos](#).

Inicio del trámite

- La solicitud del subsidio es ingresada al sistema por su prestador de salud, a partir de las 32 semanas de embarazo. Ud. recibirá una constancia del trámite con el período de licencia maternal a gozar.
- La liquidación del subsidio se hará con las remuneraciones que la empresa ingresa al sistema.
- Las trabajadoras que atiendan su embarazo en el Hospital Policial y el Hospital de las Fuerzas Armadas, podrán solicitar el subsidio maternal en las sucursales y agencias de BPS.

Modificación de inicio de licencia

Adelanto de parto: si el parto se produce entre el inicio de la licencia y la fecha probable de parto inclusive, el período de licencia se mantiene sin tener que realizar ningún trámite.

Cuando el nacimiento se produzca antes del inicio de la licencia maternal y a partir de las 34 semanas de gestación, la licencia iniciará el día del parto y finalizará al completar las 14 semanas.

Parto prematuro: cuando el nacimiento se produzca hasta las 33 semanas de gestación inclusive, la licencia iniciará el día del parto y se podrá prolongar hasta completar las 18 semanas o las 8 semanas posteriores a la fecha probable de parto inicial si este último venciera con posterioridad.

Atraso de parto: si el nacimiento se produce después de la fecha probable de parto, se extiende el período de descanso posparto considerando la cantidad de días de atraso existentes.

Prórroga: el médico podrá autorizar la postergación del inicio de la licencia maternal (prórroga), indicando la nueva fecha en el certificado.

Conocimiento del embarazo por el empleador

En cuanto a la protección durante el período de embarazo, la doctrina y jurisprudencia predominantes han requerido como condición indispensable para que se torne exigible la indemnización especial, el conocimiento del estado de gravidez por parte del empleador.

La postura antes mencionada ha sido seguida de manera casi unánime por la jurisprudencia laboral, la que ha expresado que no puede recibir una sanción especial quien desconoce que transgrede una prohibición legal por desconocer que la trabajadora cursaba un embarazo al momento de despedirla. También ha dicho que una interpretación contraria a la anteriormente señalada, en lugar de ser favorable a la situación laboral de la mujer, es perjudicial a ella puesto que coadyuvaría a optar por un trabajador, teniendo en cuenta que si contrata a una trabajadora, asume una responsabilidad objetiva de no despedir, dado que por ser mujer puede estar embarazada en algún momento¹³. En general, se ha señalado que corresponde a la trabajadora acreditar que el empleador está en conocimiento del estado de gravidez al momento de decidir su despido, debido a que no puede pretenderse que sea el patrono el que aporte la prueba imposible de un hecho negativo (ignorancia de la gravidez). En ese orden, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 3º turno ha dicho que «es de cargo de la trabajadora grávida el probar el conocimiento directo del empleador acerca del embarazo y ello no se asume por inferencias ni en aplicación de la regla *in dubio pro operario*».

En otro orden, es preciso señalar que la jurisprudencia ha sido flexible en la apreciación de la prueba del conocimiento del empleador, constituyendo un criterio frecuentemente utilizado el de la «notoriedad del embarazo» para dar por suficientemente acreditado tal extremo, lo que generalmente acontece al quinto mes de embarazo¹⁸, salvo que la propia trabajadora lo niegue y oculte.

Además, corresponde anotar que se entiende cumplido el requisito del conocimiento de la gravidez no solamente cuando el mismo se deposita en la

figura del empleador stricto sensu, sino también en su personal de confianza (gerentes, capataces, supervisores, etc.).

A ese respecto, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 3.er turno entendió que no correspondía el pago de la indemnización especial si la notificación del estado de gravidez se hizo recién al momento de comunicarse el despido. El tribunal señala, a nuestro juicio con acierto, que el despido se perfecciona cuando la comunicación del mismo llega al trabajador y este toma conocimiento del acto, por lo que se torna irrevocable, salvo que el empleador libremente decida lo contrario.

Indemnización especial

El art. 17 de la ley n.º 11.577 dispone que la violación de la estabilidad laboral de la trabajadora grávida trae aparejado que el patrón deba satisfacer un importe equivalente a seis meses de sueldo, más la indemnización legal que corresponde. Esta indemnización especial tiene carácter sancionatorio, ya que se exige el conocimiento del embarazo por el empleador para que la indemnización se devengue, pero además, es independiente de la indemnización común por despido y eventualmente acumulativa con la misma.

En efecto, existe coincidencia en cuanto a que aun cuando la trabajadora no tenga derecho a cobrar la indemnización común prevista en las leyes de 1944, igualmente el empleador tiene la obligación de servir la indemnización especial. Los ejemplos más claros de esta situación son los de la jornalera que no cumplió la cantidad de 100 jornadas, que es el mínimo requerido para acceder a la indemnización común, o la trabajadora doméstica, que para tener derecho a cobrar dicha indemnización debe haber cumplido un año en el empleo. En ambos casos se ha sostenido que igualmente tienen derecho a percibir la indemnización especial, si se cumplen las condiciones previstas en los arts. 16 y 17 de la ley n.º 11.577, ya que se trata de indemnizaciones autónomas

En el caso de las trabajadoras que perciben una retribución fija mensual (sueldo), la aplicación de la norma antes mencionada no ofrece dificultades: la indemnización se calcula multiplicando la retribución fija nominal por seis. Distinta es la situación en el caso de las trabajadoras jornaleras, destajistas o con retribución variable (por ejemplo comisionistas), ya que las mismas no perciben un «sueldo».

En el caso de la trabajadora jornalera, la indemnización se calculará determinando la cantidad de jornales que realiza habitualmente en el mes (por lo general, 25). Tratándose de destajistas o de trabajadoras con retribución variable, se deberá establecer el ingreso promedio mensual de los últimos doce meses previos al egreso. El monto de la indemnización será el resultado de multiplicar el ingreso mensual («sueldo») de la trabajadora por seis.

Causales de exoneración Los arts. 16 y 17 de la ley n.º 11.577 no establecen de forma expresa ninguna forma de excepcionamiento en caso de despido de la trabajadora grávida o que ha dado a luz, lo que ha llevado a que una corriente de opinión doctrinaria y jurisprudencial, sostenga que la ley ha consagrado un régimen de responsabilidad objetiva del que deriva la presunción absoluta de que todo despido es motivado en la maternidad. Sin embargo, la postura que puede considerarse prevalente ha admitido ciertas causales de exoneración de responsabilidad patronal. La primera causal de exoneración, a la que ya se ha hecho referencia en este trabajo, se relaciona con la ausencia de conocimiento del estado de gravidez por parte del empleador. La segunda causal de excepcionamiento, que ha tenido recepción en la doctrina y jurisprudencia predominantes, se vincula con la existencia de notoria mala conducta. Plá Rodríguez señala que si no se admitiese esta causal de exoneración la trabajadora embarazada tendría una especie de patente de corso para tomar cualquier actitud, segura de que no podría ser sancionada y se dejaría la posibilidad de cobro de una indemnización extraordinaria en manos de la propia beneficiaria, que con su comportamiento podría provocar la crisis del contrato³¹. En la misma dirección, la jurisprudencia nacional ha dicho que el único requisito para que la indemnización especial se aplique es el conocimiento por parte del empleador del estado de gravidez, no importando las causas que pudieron incidir en la determinación del despido, excepto que se pruebe que la ruptura del contrato obedeció a la trabajadora incurrió en notoria mala conducta.

También se ha dicho que si la ley exonera al empleador del pago del despido cuando se configura una causal rescisoria justificada imputable al trabajador, dicha exoneración se extiende al pago de la indemnización especial porque la responsabilidad de la rescisión del contrato recae exclusivamente en la persona del trabajador, acotándose que la circunstancia de que se trate de una trabajadora madre no implica que esta deje de ser responsable por su inconducta laboral.

La tercera causal exoneratoria de responsabilidad patronal que se des prendería de la propia mecánica del régimen legal bajo examen, se verificaría cuando existe

imposibilidad física o síquica de la trabajadora para continuar cumpliendo sus tareas habituales. En tal sentido, la ley n.º 11.577 establece que una vez finalizada la licencia maternal el empleador debe reintegrar a la trabajadora a su cargo y conservar su trabajo, si la misma «retornare en condiciones normales». De verificarse la imposibilidad mencionada, el contrato de trabajo se extinguiría por causa no imputable al empleador por lo que no correspondería el pago de ninguna indemnización. En puridad, en tal caso no existiría una situación de despido sino de rescisión del contrato por causas no atribuibles al empleador. La última causal, sobre la que existe discrepancia tanto en doctrina como en jurisprudencia, se refiere a si cuando el despido no tiene causa, motivo o vinculación con el embarazo, el empleador se exonera de pagar la indemnización especial. Ejemplo típico de este tipo de situación es cuando existe un cierre de empresa, establecimiento, sección o despido colectivo.

En jurisprudencia, la postura mayoritaria parece ser aquella que se afilia a la opinión de que no interesan los motivos por los cuales el empleador despidió a la trabajadora. Así, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2.º turno ha dicho que «debido al carácter tuitivo la norma se aplica independientemente de cuáles sean las características del despido o las razones que lo provocan» (sentencia n.º 125/98). También se ha indicado que lo que se busca proteger es a la mujer embarazada, sancionándose el despido en ocasión del embarazo y no a causa del embarazo, razón por la que no interesan los motivos ni se debe probar el nexo causal, siendo procedente la indemnización aún en caso de cierre del establecimiento.

Para otra corriente jurisprudencial minoritaria, la indemnización especial solo se debe si la ruptura del contrato obedece al embarazo, admitiéndose la exoneración en caso de cese de un sector de una planta.

Despido especial y despido indirecto: su compatibilidad

Por sentencia 364 del 12 de noviembre de 1997 dictada por la Suprema Corte de Justicia señala que el despido indirecto no es un «autodespido» y que «sería muy fácil para el empleador eludir el pago de la indemnización prevista legalmente tornando insostenible la continuación de la trabajadora embarazada en su desempeño laboral para obligarla a ella misma a renunciar. Logrando así, en forma indirecta, evadir la finalidad del instituto, cual es la conservación del empleo en tal especial circunstancia. Por lo tanto, corresponde la aplicación de la norma legal invocada en todos los casos, sin que sea necesario distinguir si el

despido fue expreso o indirecto. La objeción principal planteada por la Sala de mérito de que la trabajadora pueda, en cierta forma, elegir la fecha del despido al no configurarse el mismo hasta que no sea invocado, carece de sustento». Los argumentos desarrollados precedentemente han sido seguidos por la mayoría de los juzgados laborales (tanto de Montevideo como del Interior) y los tribunales de apelaciones del trabajo, de suerte que en la actualidad puede afirmarse que la jurisprudencia predominante admite la procedencia de la indemnización especial en situaciones de despido indirecto, siempre que el incumplimiento del empleador haga insostenible la relación laboral para la trabajadora grávida y no se trate de una situación que se ha originado en tiempo anterior al embarazo.

Otro aspecto controvertido que ha despertado especial interés se refiere a las características que debe tener el reintegro de la trabajadora grávida, después de cumplido el período de licencia maternal. La parquedad de la norma legal, que solo establece que el empleo deberá ser conservado si retornare en condiciones normales, ha generado que las «condiciones» en que el empleador debe cumplir el reintegro hayan tenido que ser elaboradas y establecidas por la jurisprudencia. La primera característica que se ha señalado al respecto es que el reintegro debe ser real y efectivo. En general se entiende que el envío al seguro de paro o el otorgamiento inmediato de la licencia reglamentaria no se toman en cuenta como reintegro efectivo⁴⁵, por lo que no se computan para el período de estabilidad. Se señala que la norma legal no consagra el derecho a la inamovilidad pero sí la conservación del empleo si la trabajadora retornare en condiciones normales, lo que no se cumple si la reincorporación es meramente formal y no sustancial. Por ello, solo se toman en cuenta a los efectos del cómputo del período de estabilidad aquellas etapas en las que existe trabajo efectivo. Naturalmente, lo anterior no implica que el empleador no tenga el derecho de enviar a la trabajadora que ha dado a luz al seguro de desempleo o el derecho de otorgarle su licencia reglamentaria anual, que aún no ha gozado. En tales casos no existe incumplimiento del empleador de la garantía de estabilidad prevista en la ley n.º 11.577, pero los lapsos en que la trabajadora permanezca amparada al seguro de desempleo o en goce de licencia reglamentaria suspenderán el curso del período de estabilidad, el que recién se iniciará una vez que se verifique trabajo efectivo. La obligación de conservar el empleo también supone que el empleador debe mantener las condiciones laborales que tenía la trabajadora previa a que se suspendiera el contrato de trabajo por motivo de la licencia maternal. En términos generales, la jurisprudencia ha entendido que el empleador debe mantener las

condiciones habituales de la trabajadora, lo que comprendería el salario, la categoría, el horario, el lugar y las demás prestaciones laborales.

La ley n.º 11.577 no establece el plazo durante el cual el empleador no puede despedir a la trabajadora madre, una vez operada la reincorporación a su puesto de trabajo. La norma legal se limita a señalar que el empleo deberá ser conservado si la trabajadora retornare en condiciones normales, lo que ha llevado a que la jurisprudencia haya tenido que llenar el vacío que dejó el legislador. El criterio usual que maneja la jurisprudencia es que debe tratarse de un «período razonable».

Como quiera que sea, parecería que no existiendo un plazo fijado legalmente la tarea de establecer el mismo corresponde en cada caso al juez. A tales efectos, este deberá recurrir a los mecanismos y principios de interpretación e integración previstos en el Derecho laboral y en los arts. 16 y 17 del Código Civil. En aplicación de estos últimos y del principio de razonabilidad parecería que mientras no exista una solución legal expresa la más adecuada sería establecer el plazo de estabilidad en 180 días, contados desde la reincorporación efectiva de la trabajadora, ya que los bienes tutelados (protección de la madre y su hijo) hacen necesaria una extensión temporal amplia de la obligación de conservación del empleo. Por ello, no parece acertada la postura que establece el momento de arranque de la protección en la fecha del parto, ya que la estabilidad tiene sentido recién cuando la trabajadora reingresa a sus tareas habituales.

Despido especial en los casos de contratación a término y a prueba

Por último, analizaremos si el despido especial es procedente en hipótesis de contratos a término que se agotan naturalmente por cumplimiento de su condición y el contrato a prueba, que se rescinde antes de cumplirse el período estipulado para el ensayo. En el caso de los contratos de trabajo de duración determinada (plazo, obra, suplencia, zafra, eventualidad, etc.) la posición ampliamente mayoritaria es que no corresponde la indemnización por no existir despido sino agotamiento natural del contrato.

La cuestión se torna mucho más compleja y controvertida cuando se trata de contratos de trabajo a prueba. Para una posición, se admite la procedencia de la indemnización especial por maternidad aun cuando el cese se verifique dentro del período de prueba.

Los argumentos de esta posición pueden sintetizarse de la siguiente forma: a) El texto de la ley n.º 11.577 no excluye a los trabajadores a prueba, por lo que el intérprete no está autorizado a realizar distinciones que no ha hecho el legislador trabajador;

b) La norma es de orden público, involucra principios constitucionales en orden a la salud y a la mujer y está dirigida a establecer una protección especial por razones biológicas y sociales; c) Nada justifica que prevalezca el plazo del contrato a prueba por sobre las normas prohibitivas de carácter general; d) En aplicación del principio de buena fe no puede aceptarse que el patrono rescinda el contrato sin solución indemnizatoria, máxime si este tiene conocimiento expreso del embarazo. De lo contrario, se abriría la puerta para la discriminación de la trabajadora grávida por la vía de la admisión de la rescisión basada en la naturaleza a prueba del contrato. Para la postura que puede considerarse minoritaria, el cese de la relación laboral durante el período de prueba no genera derecho a cobrar indemnización especial. Los argumentos que se exponen son similares a los mencionados para el caso de contratación a término.

Despido especial por enfermedad

La normativa legal también contempla la tutela de la estabilidad en el empleo del trabajador enfermo. En tal sentido, el art. 23 del decreto-ley n.º 14.407 dispone que «Las empresas no podrán despedir ni suspender al trabajador que esté ausente por razones de enfermedad si ha cumplido los requisitos que establece esta ley y su reglamentación quedando obligadas a reincorporarlo a sus tareas habituales toda vez que haya sido dado de alta por ASSE. El trabajador dado de alta no podrá ser despedido antes de que transcurran treinta días de su reincorporación a la empresa. La violación de esta obligación traerá aparejado que el pago de la indemnización por despido sea el doble de la normal, salvo que él empleador demuestre la notoria mala conducta del trabajador o que el despido no esté directa o indirectamente vinculado con la enfermedad o accidente de trabajo».

La infracción a la norma no trae aparejado la nulidad del despido sino la obligación de abonar al trabajador una indemnización especial, equivalente al doble de la común.

De la norma legal surgen tres obligaciones para el empleador: a) la prohibición de despedir o suspender durante el período de licencia por enfermedad; b) el deber de reintegrar a las tareas habituales de forma inmediata al alta médica; c) y no despedir durante 30 días posteriores a la reincorporación.

Alcance temporal de la protección

La jurisprudencia ha interpretado, a nuestro juicio de manera acertada, que el plazo de estabilidad de 30 días que establece el texto legal refiere a días corridos o calendario y no días hábiles o laborables, y que la licencia anual no se computa para ese período.

Aunque la norma legal guarda completo silencio, se ha interpretado de forma pacífica que el empleador solo cumple con su obligación de reintegrar al trabajador luego del alta médica, si se respetan todas la cualidades que tenía el puesto de trabajo antes de haberse suspendido la relación laboral por la enfermedad⁶⁸. Esto quiere decir que el empleador debe mantener las mismas condiciones de trabajo que gozaba el trabajador antes de su enfermedad, tales como categoría, lugar, horario, nivel y tipo de remuneración, etc.

Bajo la máxima de que el reintegro al trabajo debe ser real y efectivo, los tribunales han interpretado de diversa manera la posibilidad de enviar al trabajador al seguro de paro durante el período de estabilidad de 30 días corridos. Algunos fallos⁷⁰ han sostenido que el empleador no puede enviar al trabajador al seguro de desempleo porque el art. 23 del decreto-ley 14.407 dispone que el empleador no puede despedir ni «suspender» al trabajador enfermo, señalándose que esta última palabra debe interpretarse en un sentido amplio, incluyendo la prohibición de suspender la relación de trabajo a causa de falta de trabajo. Para otra postura, en cambio, no existe incumplimiento alguno si el empleador envía al trabajador al seguro de paro durante el plazo de estabilidad, pero la relación laboral queda suspendida durante ese período, lo que implica que una vez que el trabajador retorne del seguro de desempleo se continuará con el cómputo del tiempo restante para completar los 30 días corridos de estabilidad.

Sanción por infracción de la prohibición de despedir o suspender

De acuerdo al art. 23 del decreto-ley 14.407, la inobservancia de la prohibición de despedir o suspender al trabajador enfermo traerá aparejada la obligación de pagar al trabajador una indemnización equivalente al doble de la normal. Sobre el punto la jurisprudencia ha entendido que esta indemnización no es complementaria de la indemnización común prevista en las leyes de 1944, sino que es sustitutiva de la misma.

En función de este criterio, es evidente que si el trabajador no tiene derecho a cobrar la indemnización común, tampoco le corresponderá la indemnización

especial (por ejemplo, es el caso del jornalero con menos de 100 jornales en el establecimiento y los trabajadores a prueba). También es unánime la jurisprudencia en cuanto a exigir que el trabajador haya certificado su enfermedad de la manera que establezca la reglamentación vigente, por lo que no alcanza con que el trabajador haya estado enfermo para que surja la protección laboral. Por esa razón, frecuentemente se rechazan reclamaciones de despido especial cuando el trabajador no acredita que certificó su enfermedad ante la Institución médica de la cual es afiliado. La misma indemnización corresponde en caso de que el trabajador se haya considerado despedido indirectamente a causa de que el empleador no cumplió con su obligación de reintegrar en forma real y efectiva, conservando las condiciones laborales anteriores.

Si bien inicialmente se sostuvo que era incompatible la indemnización especial con el despido indirecto, ya que se temía que el trabajador pudiese aprovechar esta oportunidad para reclamar la misma aun cuando el incumplimiento alegado no tuviese ninguna vinculación con la enfermedad, la interpretación luego evolucionó y hoy día se acepta pacíficamente que la indemnización doble es procedente en caso de despido indirecto. Sin embargo, para evitar el temor que señalaban los tribunales, se entiende que la indemnización especial solo corresponde en hipótesis de despido indirecto si el empleador violó su obligación de reintegrar al trabajador en forma real y efectiva luego de que el trabajador se presentó a trabajar luego del alta o si introduce cambios en la relación laboral durante el período de estabilidad, perjudicando al trabajador. Por lo tanto, si el trabajador se considera indirectamente despedido invocando incumplimientos originados con anterioridad a la enfermedad (por ejemplo, el no pago de horas extras), no corresponde el pago de la indemnización especial aunque el cese se verifique durante el período de estabilidad. La empresa se exonera de responsabilidad si demuestra que el despido, ocurrido durante el período de estabilidad, se debe a razones no vinculadas directa o indirectamente con su enfermedad (razones organizativas, tecnológicas, rendimiento del trabajador, etc.). Así, a vía de ejemplo, la Suprema Corte de Justicia ha dicho que si el despido fue comunicado por el empleador antes de que el trabajador haya comunicado su enfermedad, no existe nexo causal alguno con esta situación por lo que no corresponde la indemnización especial.

Por otra parte, no hay duda alguna que si el despido obedece a notoria mala conducta, la indemnización especial no es procedente, siendo la prueba de que el trabajador incurrió en falta grave de parte del empleador.

De igual modo, corresponde tener presente que según lo dispuesto en el art. 16 del decreto-ley 14.407, si el trabajador continúa amparado al seguro de enfermedad más de dos años y «la enfermedad que padece el asegurado no le permite volver a ejercer sus actividades laborales, cesarán sus derechos a los beneficios del organismo, pudiendo ser dado de baja por la empresa, sin indemnización, sin perjuicio de la cobertura que le corresponda por su invalidez o desocupación forzosa (Servicio de Mano de Obra y Empleo, Seguro de Desocupación o Banco de Previsión Social)».

Despido especial y contratos temporales

Otro aspecto no regulado expresamente en la normativa bajo análisis pero sobre el cual existe posición unánime, es respecto a la improcedencia del despido especial en caso de agotamiento de un contrato de trabajo a término.

La jurisprudencia ha dicho que aplicar el art. 23 del decreto-ley 14.407 a los trabajadores temporales implicaría darles a los mismos una estabilidad que no tienen, creando de manera artificial una extensión del contrato de trabajo que no fue pactado por las partes ni querido por el texto legal⁸⁰. Esta conclusión es válida cualquiera sea la modalidad del contrato temporal que hayan libremente pactado las partes: contrato para obra determinada, contrato a plazo, contrato de zafra, contrato de temporada, contrato de beca o pasantía, etc. La misma solución se aplica indudablemente al trabajador en periodo de prueba.

Incapacidad del trabajador a causa de la enfermedad común

En virtud del contrato de trabajo, el empleado adquiere la obligación de prestar sus servicios en el lugar, tiempo y categoría profesional convenidos. A diferencia de la ley n.º 16.074 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo art. 69 establece que el empleador tiene la obligación de reincorporar al trabajador afectado de una incapacidad parcial, en un «cargo compatible» con su capacidad limitada, la legislación sobre enfermedad común guarda silencio sobre tal aspecto. No obstante ello, la opinión predominante es que el empleador debe realizar sus mejores esfuerzos por reubicar al trabajador afectado por una incapacidad parcial, en un puesto de trabajo acorde o compatible con su nueva aptitud laboral. Naturalmente, dicha incapacidad debe ser declarada por el Banco de Previsión Social, no sirviendo a tales efectos una simple opinión o dictamen emitido por el médico de la Institución médica a la cual está afiliado el empleado. Si la empresa demuestra que no posee un cargo de esas características, el contrato

de trabajo se podría considerar rescindido por imposibilidad del trabajador de cumplir con su obligación principal (trabajar).

Despido especial por accidente de trabajo o enfermedad profesional

La normativa básica sobre el punto está contenida en el art. 69 de la ley 16.074, la que dispone lo siguiente: El trabajador, víctima de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, si así lo solicita, deberá ser readmitido en el mismo cargo que ocupaba, una vez comprobada su recuperación. Si el trabajador queda con una incapacidad permanente parcial, tendrá derecho a solicitar su reincorporación al cargo que ocupaba, si está en condiciones de desempeñarlo, o a cualquier otro compatible con su capacidad limitada. Readmitido el trabajador, no podrá ser despedido hasta que hayan transcurrido por lo menos ciento ochenta días a contar de su reingreso, salvo que el empleador justifique notoria mala conducta o causa grave superviniente. El trabajador deberá presentarse a la empresa para desempeñar sus tareas dentro de los quince días de haber sido dada de alta. Si la empresa no lo readmitiera dentro de los quince días siguientes a su presentación tendrá derecho a una indemnización por despido equivalente al triple de lo establecido por las leyes laborales vigentes. El texto legal establece varias obligaciones a cargo del empleador, que pueden sintetizarse en las siguientes: a) reintegrar al trabajador luego del alta médica; b) conservar el empleo durante un período no inferior a 180 días corridos; c) si el trabajador quedó con una incapacidad laboral que le impida continuar desempeñando las tareas habituales, ofrecer otro puesto acorde a su capacidad remanente.

Al igual que sucede con el trabajador que padeció una enfermedad común, el reintegro debe ser real y efectivo y deben respetarse todas las condiciones laborales que tenía el mismo antes acogerse al amparo del Banco de Seguros del Estado. Solo pueden introducirse cambios si los mismos están plenamente justificados en motivos objetivos y serios. Al respecto, la posición que parece ser mayoritaria es que el trabajador no puede ser enviado al seguro de desempleo durante el período de estabilidad, aunque algunos fallos sostienen la postura contraria, indicando que en tal caso se suspende el cómputo de la estabilidad, el que continúa luego de finalizado el subsidio por desempleo.

Sanciones por vulnerar la estabilidad laboral

Si bien una primera lectura de la norma que se comenta puede llevar a pensar que la sanción que se le aplica al empleador que no respeta la estabilidad laboral del trabajador accidentado es la indemnización equivalente al triple de la común⁸⁸,

lo cierto es que la doctrina y jurisprudencia mayoritarias han sostenido que esta sanción se aplica solamente en los siguientes casos: a) si es despedido durante la ausencia motivada en el accidente de trabajo o enfermedad profesional; b) si una vez que es dado de alta el empleador no lo reintegra dentro de los 15 días siguientes de su presentación al empleo; c) si lo reintegra defectuosamente, sin respetar las condiciones laborales que el trabajador gozaba antes de ampararse al Banco de Seguros del Estado; d) si no se le ofrece un puesto acorde a su nueva capacidad laboral, en caso de que el trabajador quede con una capacidad limitada debido al accidente de trabajo o enfermedad profesional.

La posición ampliamente mayoritaria es que si el empleador infringe el deber de conservar el empleo durante el período de 180 días posterior al reintegro al trabajo luego del alta médica, la sanción que corresponde no es la indemnización triple sino el pago de los salarios que faltaren para completar el período de estabilidad, más la indemnización común o tarifada. Se entiende que el empleador debe otorgar trabajo y remuneración durante el plazo de 180 días corridos, por lo que si infringe este deber debe continuar pagando el salario habitual que percibía el trabajador hasta completar dicho plazo, más la indemnización tarifada según la antigüedad del trabajador. Además de los jornales caídos el empleador también deberá pagar la proporción de aguinaldo, licencia no gozada y salario vacacional que se habrían generado durante el período de estabilidad, de no haberse interrumpido el mismo de forma anticipada.

Contratos a término y a prueba

También es pacífica la postura que entiende que no corresponde la aplicación del despido triple, en caso de que la relación de trabajo cese por agotamiento del contrato de trabajo de duración determinada.

Por lo tanto, si la obra, zafra, temporada, plazo, etc. culminan durante el período de estabilidad de 180 días o inclusive durante la etapa de convalecencia del trabajador, la empresa no debe prorrogar artificialmente la vigencia de la relación de trabajo para cumplir con el plazo legal. Se entiende que si así no fuese entonces se estaría otorgando estabilidad a quien legal ni contractualmente la tiene. Así, los tribunales han rechazado reclamaciones de despido triple en caso de agotamiento de contratos a plazo, de zafra, por obra determinada o por viaje redondo.

Causales de exoneración de responsabilidad

El art. 69 de la ley n.º 16.074 establece a texto expreso que la indemnización especial no es procedente en caso de que el cese se verifique por notoria mala conducta o causa grave superviniente.

Naturalmente, la carga de demostrar la notoria mala conducta correrá por cuenta del empleador.

Más compleja es la determinación del alcance de la segunda causal de exoneración, referida a la «causa grave superviniente».

En la práctica, la justicia laboral ha sido sumamente rigurosa y restrictiva en la apreciación de las situaciones de causa grave superviniente, descartándose los casos de quiebra de la empresa, clausura de locales o filiales, disminución de ventas y situaciones similares.

Obligación de reintegrar al trabajador con capacidad limitada

El art. 69 de la ley de accidentes de trabajo regula la situación del trabajador que sufrió una incapacidad parcial permanente, a causa del accidente de trabajo o enfermedad profesional. Cuando la misma le impide al trabajador continuar desempeñando las tareas habituales, el empleador tiene el deber de ofrecer al trabajador un nuevo puesto laboral, acorde a la nueva capacidad remanente del trabajador. Si el empleador no cumple con esa obligación, deberá abonar al trabajador la indemnización especial prevista en la norma.

Ahora bien, ¿qué sucede si el empleador demuestra no tener otro puesto de trabajo acorde a la nueva capacidad del trabajador? ¿Se exonera de responsabilidad y no debe pagar la indemnización especial? La cuestión no fue resuelta a texto expreso por el legislador.

Otro punto no resuelto es cuál es la remuneración que corresponde en caso de que el empleador reubique al trabajador en un nuevo puesto laboral, que tiene adjudicado una remuneración salarial inferior a la que percibía en el puesto anterior.

En la práctica, el empleador normalmente prefiere mantener la remuneración que percibía el trabajador en su puesto anterior, de modo de no generar una posible diferencia salarial con impacto hacia el futuro, o de lo contrario, abonar una indemnización parcial calculada en función de la diferencia de remuneraciones.

En cualquier caso, lo que parece claro es que el empleador solo estaría obligado a pagar el nivel de remuneración previsto obligatoriamente para la nueva

categoría, ateniéndose para ello a los laudos o convenios vigentes, por lo que el trabajador no podría reclamar el valor que se paga a otros trabajadores de la empresa que ocupen ese cargo, si reciben una retribución superior a la que exigen los laudos o convenios.

Despido especial por acoso sexual

El mismo se encuentra regulado en la ley 18.561 del 11 de setiembre de 2009, cuyo artículo 11 establece lo siguiente: “(Indemnización). El trabajador/a víctima de acoso sexual, sin perjuicio de la denuncia administrativa y de la acción penal que pudiese corresponder, tendrá derecho a reclamar al responsable una indemnización por daño moral mínima equivalente a seis mensualidades, de acuerdo con la última remuneración del trabajador/a. El trabajador/a afectado podrá optar por la indemnización prevista en el inciso precedente o por considerarse indirectamente despedido/a, en cuyo caso el despido revestirá el carácter de abusivo y dará derecho a una indemnización especial tarifada de seis mensualidades, de acuerdo con la última remuneración del trabajador/a, la que será acumulable a la indemnización común”.

El artículo 4 de la ley dispone que el empleador es responsable por los actos de acoso sexual realizados de forma directa por el mismo, pero también por los ejecutados por sus mandos medios, sus dependientes y por cualquier otra persona vinculada al lugar de trabajo. La solución es compartible ya que no existe discusión respecto a que el empleador es garante de la seguridad, higiene y moralidad de los lugares de trabajo, incluyendo obviamente los actos de acoso moral y sexual que puedan haber realizado los jefes, encargados, capataces, gerentes y cualquiera de sus dependientes. Sin embargo, es preciso aclarar que tratándose de actos de acoso cometidos por sus empleados, representantes o terceros, el empleador solo será responsable cuando «haya tenido conocimiento de su ocurrencia y no haya tomado las medidas para corregirlas» (inciso 2 del artículo 4), por lo que se trata de una responsabilidad subjetiva, basada en culpa, la cual se configura solo en caso de que no adopte las medidas correctivas propias de la diligencia media de un buen empresario. Ello implica que el trabajador debe haber puesto en conocimiento del empleador las medidas de acoso sexual realizadas por los mandos medios, o compañeros de trabajo.

Los tribunales laborales, al igual que la doctrina, han entendido que los actos de acoso sexual realizados por los dependientes, cualquiera sea la jerarquía del mismo, configura una hipótesis de notoria mala conducta. Asimismo, han

sostenido que si el empleador toma conocimiento de un acto de acoso sexual y no despidió al trabajador que incurre en ese comportamiento o lo sanciona seriamente, puede comprometer su responsabilidad frente al trabajador víctima del acoso ya que esa no es la conducta esperable para el caso.

Indemnizaciones especiales

Cuando el trabajador demuestra que fue víctima de un acto de acoso sexual, el texto legal que se examina prevé una opción a favor del mismo: a) mantener el vínculo laboral y reclamar al responsable una indemnización por daño moral, que la ley fija en una cantidad mínima equivalente a 6 mensualidades de acuerdo con la última remuneración del trabajador víctima del acoso; o b) considerarse indirectamente despedido, en cuyo caso el cese tendrá carácter de abusivo y dará derecho a una indemnización especial tarifada de 6 mensualidades, de acuerdo con la última remuneración del trabajador, la que será acumulable a la indemnización común.

En el primer caso, la reparación del daño moral recae sobre el responsable del acto de acoso sexual, que según se dijo puede ser el propio empleador, pero también sobre un tercero, como es el caso de otro dependiente de la empresa, lo que implica que el trabajador podrá reclamar judicialmente de forma directa contra este. Aunque la norma no lo aclara, parece evidente que si el empleador incurrió en culpa por haber conocido los actos de acoso y no haber adoptado medida represiva alguna, también podrá ser sujeto pasible de una reclamación de daño moral, lo que podrá hacerse de forma acumulativa o independiente del reclamo contra el responsable directo.

A su vez, Martha Márquez expresa que «las personas víctimas de acoso sexual, si optan por conservar el puesto de trabajo, tendrán derecho a reclamar al responsable una indemnización por daño moral mínima equivalente a 6 mensualidades de acuerdo a la última remuneración del trabajador» y que «se deberá probar la ocurrencia del acoso, y el responsable del mismo, solicitando se condene a la reparación del daño moral sufrido, de acuerdo al criterio fijado por la ley»¹¹⁰. Resulta claro entonces que la carga de demostrar los actos de acoso sexual recae sobre el trabajador denunciante, más allá de la flexibilidad que pueda aplicar el tribunal en la apreciación de la prueba, que por regla será de carácter indiciario.

El monto de la indemnización es fijado por la ley en un mínimo de 6 veces el monto de la retribución que percibe mensualmente el trabajador, según el último

valor de la misma. Para el cálculo de esa retribución se deberá tomar en cuenta el sueldo, jornal o promedio de destajos que perciba mensualmente el trabajador, sin adicionar otras partidas marginales que pueda recibir eventualmente (horas extras, incentivos, bonos, etc.), salvo aquellas que sean fijas y permanentes (como la prima por antigüedad o el incentivo por presentismo, si siempre se percibe). El texto legal es claro en cuanto a que la reparación de 6 mensualidades es un «mínimo», por lo que quedará a la ponderación del tribunal la posibilidad de fijarla en un monto superior en atención a la gravedad y otras circunstancias relevantes del caso.

Como se dijo, la otra alternativa que se le abre al trabajador víctima del acoso es considerarse indirectamente despedido, en cuyo caso el despido revestirá el carácter de abusivo, fijándose dos indemnizaciones a favor del trabajador: a) una equivalente a 6 mensualidades, calculada en función de la última retribución del trabajador, por el daño moral sufrido por el mismo y, b) otra equivalente a la indemnización común o tarifada que establecen las leyes de despido del año 1944.

Despido por violencia de género

El art. 4 de la ley define la violencia basada en género como una forma de discriminación que afecta, directa o indirectamente, la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como la seguridad personal de las mujeres.

El art. 6 en su lit. I, se refiere en especial a la violencia laboral, es decir aquella violencia ejercida en el contexto laboral, por medio de actos que obstaculizan: a) el acceso de una mujer al trabajo; b) el ascenso o estabilidad en el mismo, tales como el acoso moral, el sexual; c) la exigencia de requisitos sobre el estado civil, la edad, la apariencia física, la solicitud de resultados de exámenes de laboratorios clínicos, fuera de lo establecido en los marcos legales aplicables; d) la disminución del salario correspondiente a la tarea ejercida por el hecho de ser mujer.

Finalmente, el art. 40 de la ley n.º 19.580 establece una serie de reglas para asegurar la permanencia en el trabajo de las mujeres en situación de violencia basada en género. Se señalan en especial las siguientes: a) derecho a percibir el salario íntegro por el tiempo que conlleve la asistencia a trámites judiciales dispuestos en el ámbito de la aplicación de la ley; b) licencia con goce de sueldo por 24 horas a partir de denuncia en sede policial o judicial; c) flexibilidad del

horario laboral en la medida de lo posible; medidas de protección que se adopten en el marco de la ley no deben afectar la carrera funcional; d) estabilidad laboral.

Estabilidad laboral y despido especial

El lit. F del art. 40 introduce un plazo de estabilidad para situaciones de violencia, sufridas por la mujer. La norma expresa: Las mujeres víctimas de violencia basada en género tienen los siguientes derechos: [...] f) A la estabilidad en su puesto de trabajo. Por un plazo de seis meses a partir de la imposición de medidas cautelares por hechos de violencia basada en género, las mujeres en favor de quienes se hubieran dispuesto no podrán ser despedidas. Si lo fueren, el empleador deberá abonarles un importe equivalente a seis meses de sueldo más la indemnización legal que corresponda.

El «disparador» del derecho es la denuncia judicial de la situación e imposición por el juez de medidas cautelares de protección contra el agresor. En los ejemplos indicados, la mujer deberá obtener medidas cautelares con relación a su pareja o al presunto agresor, para que se le reconozca el derecho a la estabilidad.

or tal motivo, es importante que la víctima ponga en conocimiento del empleador el hecho de la situación que está viviendo y la denuncia promovida, aunque sea por medios tan comunes como un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp.

Despido por trabajo nocturno

El art. 4 de la ley n.º 19.313 establece que se calificará como trabajo nocturno a los efectos normativos, el que se cumpla por más de cinco horas consecutivas por jornada de labor, entre las 22 horas y las 6 horas del día siguiente, sin perjuicio de lo que puedan establecer leyes especiales o laudos de los Consejos de Salarios. El art. 3 indica que el trabajo nocturno, definido en los términos del art. 4, se retribuirá con una sobretasa mínima del 20 % o su equivalente en reducción horaria.

Cambio de horario de la mujer grávida y proyección sobre el despido indirecto

El art. 2 de la ley n.º 19.313 expresa: «a la mujer grávida o que ha dado a luz, hasta un año posterior a su alumbramiento, se le asignará horario de trabajo diurno por parte del empleador, por la sola voluntad de la trabajadora, sin que esto signifique pérdida de la compensación por trabajo nocturno».

La norma conserva analogía con lo establecido por la ley n.º 17.215 del 24/09/1999, que reconoció el derecho de la trabajadora embarazada a cambiar

temporalmente de trabajo, cuando sus normales actividades pudieran poner en riesgo su salud o la del hijo.

En el caso del trabajo nocturno, la trabajadora no deberá probar que las tareas implican un perjuicio para su salud o la del hijo: alcanza la situación objetiva de trabajo nocturno (siempre que se ajuste al concepto legal), para solicitar el cambio. La norma nada más agrega, pero entendemos que es posible aplicar por vía analógica lo expresado por el art. 2 de la ley n.º 17.215: las trabajadoras que ejerzan este derecho no podrán por tal causa «ser suspendidas, despedidas, perjudicadas en sus derechos laborales ni postergadas en su carrera funcional» (art. 2). Cabe señalar que el decreto reglamentario 234/015 del 31/8/2015 establece que el empleador dispone de un plazo de 20 días corridos para dar cumplimiento al cambio peticionado, el que se computa desde que tuviera conocimiento de la opción (art. 7, inc. 3). Entendemos que de no cumplir con la solicitud de cambio de la trabajadora, esta podrá considerarse indirectamente despedida, con la agravante de poder generar la indemnización especial por maternidad.

La norma expresa que el derecho de la trabajadora a solicitar la modificación de su horario se extiende «hasta un año posterior a su alumbramiento». Para evaluar el monto del despido indirecto, deberemos diferenciar dos situaciones, en virtud de la combinación del art. 2 de la ley 19.313 y el art. 17 de la ley 11.577 de 14/10/1950: a) si la trabajadora solicita el cambio de horario en algún momento de los seis meses siguientes a su reincorporación y no se le autorizara, de considerar se despedida tendrá derecho al despido común más el especial; b) si la solicitud de cambio se produjera luego de los seis meses posteriores a la reincorporación, pero antes del vencimiento del año posterior a su alumbramiento, la negativa de cambio dará lugar al despido indirecto común, sin el «plus» del despido especial.

El despido especial previsto por el Convenio OIT n.º 171 Como expresáramos, nuestro país ratificó en el año 2017 (dos años después de la aprobación de la ley) el Convenio Internacional del Trabajo n.º 171. El referido documento establece en su art. 6: Los trabajadores nocturnos que, por razones de salud, sean declarados no aptos para el trabajo nocturno serán asignados, cuando sea factible, a un puesto similar para el que sean aptos. Si la asignación a tal puesto no es factible, se concederán a estos trabajadores las mismas prestaciones que a otros trabajadores no aptos para trabajar o que no pueden conseguir empleo. La norma asimila la imposibilidad de realizar tareas nocturnas por razones de salud a la situación de

la enfermedad común, por lo cual nos conecta directamente con el decreto-ley 14.407 y con sus reglas relativas a subsidios, suspensión del contrato y —en lo que nos ocupa en este trabajo— la situación del despido especial. El art. 6 en su numeral 3 agrega que el trabajador declarado temporal mente no apto para el trabajo nocturno «gozará de la misma protección contra el despido o la notificación del despido que los demás trabajadores que no pueden trabajar por razones de salud».

Entendemos que el Convenio considera los problemas de salud generados específicamente por el trabajo nocturno, como una sub-causa de enfermedad.

La norma del Convenio —como muchas veces acontece con este tipo de reglas— tiene cierta flexibilidad, porque el deber del empleador encuentra su límite en que sea «factible» el cumplimiento del cambio de tareas. Para el caso de que el cambio no sea factible, el trabajador podrá recibir las prestaciones que concede el decreto-ley 14.407, siendo de aplicación el art. 23 del mismo, al ser dado de alta. El texto parece aludir también a la posibilidad que se opte por el seguro de desempleo, pero entendemos que el Convenio 171 deberá combinarse con la normativa nacional más adecuada, en nuestro caso aquella que regula la enfermedad común.

Despido del trabajador con discapacidad

La Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13/12/2006, ratificada por ley n.º 18.418 del 20/11/2008, elabora un concepto comprensivo de las diversas situaciones físicas y mentales que limitan la participación de las personas en la sociedad: «Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás». A su vez la ley n.º 18.651 de 19/2/2010, en su art. 2 expresa: «Se considera con discapacidad a toda persona que padezca o presente una alteración funcional permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o psíquica) que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral».

La ley 19.161 que entró en vigencia el 18/11/2018, es un instrumento importante para promover la inclusión en el trabajo de las personas con discapacidad, al establecer un régimen de «cuotas progresivas» de incorporación en las contrataciones laborales de la actividad privada. El art. 1 expresa: «Los

empleadores de la actividad privada que cuenten con 25 (veinticinco) o más trabajadores permanentes, en todo nuevo ingreso de personal que se produzca a partir de la vigencia de la presente ley, deberán emplear a personas con discapacidad».

El art. 9 de la ley 19.691 establece que solo podrá despedirse una persona con discapacidad, por una causa razonable, relacionada con la conducta del trabajador o las necesidades de la empresa. No existe como otras hipótesis de despido especial un plazo que garantice la estabilidad en el empleo, sino que —a semejanza de la situación del militante sindical— se establece un despido causado, que no está vinculado a un plazo determinado. En otras palabras, nos encontramos ante un plazo de estabilidad por tiempo indefinido.

La «prohibición de despedir» no se sanciona con la reincorporación, sino con el pago de un despido especial equivalente a seis meses de «salario» más la indemnización legal.

Viajante y vendedor de plaza

En opinión de Américo Plá Rodríguez, que es seguida por la abrumadora mayoría de la doctrina y jurisprudencia de nuestro país, si bien la intención de la Ley número 14.000 fue establecer que todos los viajantes o vendedores de plaza son dependientes y no puede haber viajantes autónomos, esa conclusión no surge del contexto general de la ley. No todas las personas que realicen las tareas propias de los vendedores o viajantes deben considerarse comprendidas en el régimen de las leyes número 14.000 y 12.156, admitiéndose pacíficamente que no se eliminó o derogó la figura del vendedor autónomo. Un breve repaso de nuestro principal repertorio de jurisprudencia laboral nos permite afirmar, sin temor a equivocarnos, que la justicia especializada rechaza la interpretación que sostiene que todos los vendedores son necesariamente empleados, sin importar si se verifica la presencia de subordinación jurídica o no.

el Prof. Américo Plá Rodríguez expone diversas pautas o datos que pueden relevar la existencia o ausencia de subordinación jurídica:

a) si el vendedor debe ajustarse estrictamente a las instrucciones e indicaciones de la empresa o tiene libertad para seguir su propio programa de trabajo;

b) si tiene que presentar informes detallados de la inversión de su tiempo;
c) si existen elementos fijos en su retribución o solamente percibe remuneración variable;

d) si al terminar la gira presenta su lista de gastos de viaje o cobra una cantidad global por ese concepto o asume personalmente los mismos;

e) la existencia o no de exclusividad;

f) el hecho de que el vendedor se encuentre inscrito o no en el Registro de Viajantes y Vendedores de Plaza; y,

g) la posesión de escritorio independiente.

Explica Héctor-Hugo Barbagelata que los criterios, positivos y negativos, que comúnmente se utilizan para determinar si un trabajador es viajante o vendedor de plaza, son el trabajo personal, la actividad permanente, la profesionalidad, la no realización de operaciones por cuenta propia, la exclusividad, las instrucciones y el contralor de su actividad, la garantía de una remuneración mínima y reembolso de gastos y la representación.

El art. 7 de la Ley número 12.156 establece las condiciones de trabajo deben de terminarse por escrito, estando obligada la empresa a entregar a los viajantes o vendedores de plaza una copia firmada, siendo otra vía destinada a su inscripción en el Registro Nacional de Viajantes y Vendedores de Plaza.

El Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1º turno ha dicho con acierto que “la doctrina y la jurisprudencia laboralista nacional, citada por la parte ac tora adherente es clara en establecer que la falta de celebración por escrito del contrato y la falta de inscripción en el Registro respectivo es irrelevante para desvirtuar la calidad de viajante o vendedor de plaza. La Sala comparte lo ex presado por el TAT 2do. en sentencia 283/2007 en el sentido de que “la calidad de viajante o vendedor de plaza es invocable aún si no se hubiese llenado el requisito de la contratación por escrito, o la entrega del mismo al Registro Nacional de Viajante y Vendedores de Plaza.

En primer lugar, la Ley número 12.156 creó un Registro Nacional de Viajantes y Vendedores de Plaza del Comercio y la Industria, en el cual están obligadas a inscribirse todas las personas que ejerzan la actividad de Viajante o Vendedor de Plaza. Asimismo, en dicho Registro se inscribirán los contratos que celebren con los empleadores, siendo de cargo de éstos su registración. En segundo lugar, la Ley número 12.156 dispone que el Poder Ejecutivo insti tuya

una Comisión integrada por dos delegados de los empleadores, dos delegados de los vendedores y un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (art. 3). Entre otros cometidos, esta Comisión debe expedirse en toda solicitud de inscripción en el Registro de Viajantes, así como la de dirimir controversias sobre la calidad de vendedor de plaza o de viajante. La contienda puede plantearla el empleador o el trabajador o una entidad gremial.

El artículo 8 del Estatuto también prevé la figura de la denominada “comisión indirecta”. En ese sentido, establece que se debe pagar comisión aun cuando el negocio no haya sido concertado por el vendedor o viajante, siempre que se den ciertas condiciones:

- a) que se trate de negocios con clientes que le hayan sido asignados para visitar regularmente;
- b) que se trate de renglones que esté habitualmente autorizado a vender;
- c) que con ese cliente, el vendedor haya concertado o iniciado operaciones en período no mayor a 180 días para viajantes o de 60 días para vendedores de plaza; y,
- d) la tasa de comisión indirecta será igual a la directa.

En cuarto lugar, el artículo 4º de la Ley número 14.000 dispone que “salvo el caso de dolo o culpa grave del viajante o del vendedor de plaza, ni éste ni aquél, serán responsables de la insolvencia del cliente”. Ello implica que si la empresa no logra cobrar la venta al cliente, igualmente debe pagar la comisión al vendedor, salvo que éste haya incurrido en dolo o culpa grave.

En quinto lugar, la Ley número 16.678 estableció un régimen especial de actualización de las comisiones para el caso de extinción de la relación laboral, de modo de que los créditos laborales que se deben pagar en esa ocasión no se vean desvalorizados por la inflación. Así, el art. 1º dispone que En los casos de extinción del contrato de trabajo de los viajantes y vendedores de plaza el rubro comisiones, a los efectos del cálculo de la totalidad de los créditos laborales que el trabajador tenga derecho a percibir, será equivalente al promedio de las comisiones generadas en los doce meses anteriores a la fecha de la extinción contractual, actualizadas conforme al valor de la unidad reajutable correspondiente a cada mes. Si la relación laboral del viajante o vendedor de plaza cesante hubiera tenido una duración inferior a los doce meses el promedio a que

refiere el inciso anterior se efectuará tomando en cuenta el período de vigencia del contrato.

También establece que “El tiempo en que el viajante o vendedor de plaza haya estado en goce del seguro de paro no se computará para la determinación del período promedial a que refiere el artículo anterior” (art. 2). En sexto lugar, el artículo 5 de la Ley 14.000 establece un despido especial a favor de los viajantes y vendedores de plaza, conocido como “indemnización por clientela”. En concreto la norma legal dispone: En caso de despido, los viajantes y vendedores de plaza que hubieran mantenido o contribuido a aumentar el volumen de los negocios de la empresa, tendrán derecho a recibir una indemnización por clientela cuyo monto será equivalente al 25% (veinticinco por ciento) de la indemnización que les corresponde por despido. Ambas indemnizaciones las pierde el empleado que hubiere sido despedido por notoria mala conducta. Los viajantes y vendedores de plaza que con más de cinco años de antigüedad en el establecimiento se retiren por su voluntad, tendrán igualmente derecho a la indemnización de clientela la cual se calculará considerando al empleado que se retira como si hubiera sido despedido. Existe pleno acuerdo en que esta indemnización por clientela, que es equivalente al 25% de la indemnización que corresponde por despido común, es adicional y acumulativa con la indemnización tarifada prevista en las leyes de 1944. A su vez, la indemnización especial solo se devenga si el vendedor tiene derecho a cobrar indemnización por despido, ya que la misma se calcula sobre la indemnización tarifada.

La Ley 14.000 establece que la indemnización especial también es procedente cuando el vendedor renuncia, siempre que su antigüedad en la empresa sea mayor a 5 años.

En séptimo lugar, como nos recuerda Graciela Giuzio, cuando los viajeros y vendedores de plaza son exclusivos la Resolución número 491 de 6 de agosto de 1974 de la ex COPRIN, establece que si el vendedor de plaza no tiene locomoción propia, se le debe reintegrar el equivalente al costo de 10 boletos de ómnibus por cada día de trabajo; si tiene locomoción provista por la empresa ésta debe hacerse cargo de todos los gastos del vehículo y si utiliza su propio vehículo entonces la empresa debe acordarse, pero en ningún caso el reintegro puede ser inferior al valor de 100 litros de nafta. Por su parte, si se trata de viajeros, se le deberá reintegrar el 100% de los gastos reales de alojamiento y alimentación debidamente autorizados y documentados.

Finalmente, los viajantes y vendedores de plaza están excluidos del derecho a cobrar horas extras. Así lo dispone el Decreto número 611/80 que establece que los “viajantes y vendedores de plaza, corredores, cobradores e investigadores de cobranzas, promotores de ventas, asesores previsionales y asesores de inversión que realicen sus tareas fuera del establecimiento”.

Régimen de Despido del trabajador rural

El despido de los asalariados rurales se rige por la normativa laboral general (derecho a una indemnización legal tarifada, salvo que mediara notoria mala conducta, calculada en función de la antigüedad del trabajador con un tope de 6 mensualidades o 150 jornales), con algunas particularidades.

Todo patrono rural está obligado a facilitar al trabajador despedido, en caso que necesite por carecer de recursos, su traslado y el de su familia; así como el de sus muebles y demás efectos hasta el lugar en que haya medios regulares de transporte. De ser necesario en caso de enfermedad grave del trabajador o de algún miembro de su familia que viviera con él, cuando ello sea imprescindible por representar el traslado un riesgo para su salud, el empleador está obligado a permitir su permanencia en el establecimiento por el término que se considere necesario.

Salvo que mediara acuerdo escrito en contrario, las mejoras o los sembrados existentes en el predio, así como los animales e implementos de trabajo que se le hubieren facilitado, deberán ser dejados o entregados por el trabajador al retirarse del establecimiento; el empleador no podrá efectuar deducciones en el salario por concepto de pastoreo o cuidado de animales de propiedad de trabajador rural.

Despido de la trabajadora doméstica

Los trabajadores domésticos, tanto mensuales como jornaleros tienen derecho a la indemnización por despido “desde los noventa días corridos de iniciada la relación laboral, rigiéndose en lo demás por las normas generales de despido” conforme artículo 7º de la Ley número 18.065.

Vale destacar que esta continuidad de noventa días corridos, se cumple con independencia de la modalidad de trabajo, esto es, de los días por semana trabajados, de las suspensiones por enfermedad o accidente laboral; abarcando a todos los trabajadores del hogar, sean mensuales o jornaleros. En todo lo demás, se rigen por el régimen general.

Por Convenio colectivo del año 2008 las partes expresamente acogieron una causal de despido propia, que se suma a las previstas en la legislación nacional; el Despido parcial. El despido parcial se configura “cuando a un trabajador se le otorguen menos horas que las que cumplía en el año anterior, el empleador deberá abonar la indemnización por despido parcial correspondiente, dentro del mes en el que se rebajan las horas de trabajo” (cláusula décimo segunda). En virtud de lo cual entendemos, que la indemnización por despido parcial (IPDP) tiene razones de proporcionalidad con el salario que el trabajador deja de percibir. Debiendo el empleador pagar la indemnización, ocurrida la reducción horaria.

Despido de la trabajadora doméstica en estado de gravidez o madre reciente

El artículo 8° de la Ley número 18.065, hace un avance de significación cualitativa al establecer “la trabajadora que fuera despedida encontrándose en estado de gravidez y hasta que hayan transcurrido por lo menos ciento ochenta días de su reintegro efectivo de la licencia correspondiente, tendrá derecho a la indemnización prevista en el art. 17 de la Ley 11.577 de 14.X.1950”.

Se trata de una norma que perfecciona el régimen en relación a las trabajadoras domésticas complementando el régimen general, al disponer que la prohibición de despedir se extiende hasta 180 días de su reintegro efectivo, lo que significa que queda gravado el empleador con el despido especial equivalente al pago de seis meses de sueldo más la indemnización por despido común

Tratamiento fiscal del despido

La indemnización por despido es una de las pocas partidas no gravadas por IRPF. En efecto, el inciso 4 del artículo 32 del Título 7, del T.O de 1996, señala que sólo estarán gravadas cuando superen el monto que la ley establece para cada caso. Surge de la norma antes citada que sólo estarán exentas de tributación las indemnizaciones por despido que tenga consagración en texto legal. Por tal razón, la indemnización por despido abusivo estará gravada por IRPF, ya que su construcción es doctrinaria y no de fuente legislativa.

El sistema uruguayo plantea el debate en torno a un tema que en los últimos años ha sido especialmente polémico: al establecer las leyes de 1944 un despido tarifado, ¿debe entenderse que el empleador puede despedir a su trabajador libremente, es decir sin justa causa? ¿Existe en Uruguay el llamado (usando un

conocido latinazgo) despido ad nutum? Durante década la jurisprudencia al más alto nivel ha sostenido que el régimen nacional no exige una «justa causa» de despido, por lo que el empleador no debe expresar ninguna particular motivación para despedir. Así, por ejemplo, la Sentencia n.º 33/006 del 8/3/2006 de la Suprema Corte de Justicia reafirma criterios anteriores de la jurisprudencia —y en especial de la jurisprudencia de la propia Corte— en materia del discutido derecho de despedir y de la indemnización por despido abusivo. Expresa que en nuestro sistema laboral se consagra el despido ad nutum, es decir el despido incausado, lo que equivale a reconocer —como indica la Corte— el «derecho de despedir» por parte del empleador, cuya única astringencia es el pago de una indemnización. Sin embargo, hoy se discute sobre la aplicación en nuestro derecho de los documentos de la Organización Internacional del Trabajo: la Recomendación n.º 192 (es especial el art. 2) de 1963 y la Recomendación n.º 166 (en especial el art. 8) de 1982 y el Convenio Internacional del Trabajo n.º 158 (no ratificado por nuestro país). Este último, aprobado en la Conferencia de la OIT de junio de 1982, establece que «no se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio» (art. 4). Esta norma consagra a nivel internacional la necesidad de que el despido tenga siempre causa justificada, eliminando por lo tanto lo que se da en llamar «despido libre» o —con pomposo latinazgo— «despido ad nutum». Nuestro país —pese a ser uno de los países con mayor adhesión a los convenios internacionales del trabajo— no ha ratificado el Convenio 158. De todos modos, no debemos olvidar que en la Conferencia de Ginebra del año 1982 también se aprobó la Recomendación n.º 166 con un texto similar al del Convenio. Esto significa que si bien el despido causado (previsto en el Convenio 158) no es una norma interna asimilable a una disposición legal, el hecho que nuestro país sea miembro de la OIT determina que la Recomendación n.º 166 tiene una doble consecuencia: por un lado debe tomarse nota que la comunidad internacional «recomienda» a nuestro país aplicar las reglas contenidas en la R. 166; por otro lado, la R. 166 debe considerarse «doctrina más recibida» en materia de despido, en virtud del art. 16 del Código Civil sobre las reglas de interpretación e integración del derecho. El rango jurídico de una Recomendación de la OIT es similar al de las grandes declaraciones internacionales o regionales (Declaración Universal de Derecho Humano, Declaración Sociolaboral del Mercosur y en general de las llamadas «clausulas sociales»).

También debemos aclarar que en nuestra opinión la Recomendación 166 no consagra un derecho a la estabilidad absoluta del trabajador ni tampoco el despido sin justa causa, sino que declara el carácter ilegítimo del despido incausado, habilitando al juez a aplicar sanciones monetarias —independientes del despido tarifado— en todos aquellos casos en que el empleador no prueba una justa causa de despido.

También es pacífica la postura que entiende que no corresponde la aplicación del despido triple, en caso de que la relación de trabajo cese por agotamiento del contrato de trabajo de duración determinada.